Avertissement : *Ce document est la propriété exclusive de son auteur, M.Afif DAHER. Il est destiné aux seuls étudiants de troisième année de licence du Collège juridique franco-roumain 2015-2016. Sa reproduction et sa commercialisation présentes et futures sont strictement interdites.*

DROIT DES SOCIÉTÉS

Collège Juridique Franco-Roumain

Cours de M. Afif DAHER

Maître de Conférences Hors classe -HDR

INTRODUCTION

Définition légale de la société :

L'article 1832 C. civ. dispose que :

"*La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.*

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ".

Et la question qui se pose est de savoir quels sont les motifs qui pourraient inspirer un entrepreneur pour adopter la forme sociétaire. Pourquoi crée-t-il une société ?

Section 1. Les motifs pouvant inspirer l'adoption de la forme sociétaire

Trois motifs principaux inspirent donc l'adoption de la forme sociétaire :

§1. 1er motif : L'exercice en commun d'une activité professionnelle : organisation du partenariat

Partir toujours de l'article 1832.

La société offre **un cadre d'organisation aux partenaires** désirant exercer en commun une activité professionnelle, faire une proposition lors d'une procédure de marché public, exporter en commun,...

Exemple :

- Eurotunnel, entre la France et la Grande Bretagne
- La création de filiales communes.
- L'exercice d'une profession libérale : entre avocats, médecins, notaires...
- L'exercice d'une activité agricole au sein d'un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun Loi du 8 août 1962) ou d'une EARL.

§2. 2ème motif : La gestion indépendante des patrimoines : organisation du patrimoine et limitation des risques juridiques et financiers

Trois idées principales, nous permettent de confirmer ce deuxième motif, cette technique:

A. 1ère idée. La société offre une structure d'accueil à l'entreprise par sa personnalité morale

Le problème de l'entreprise est qu'elle n'est pas un sujet de droit. **Elle n'a pas la personnalité morale, elle n'a pas de patrimoine ; elle n'est ni créancière, ni débitrice**.

C'est la structure sociétaire lui procure la capacité juridique qui lui manque. La société apparaît ainsi comme une technique juridique d'organisation possible de l'entreprise. **Seules les personnes, physiques ou morales, peuvent avoir un patrimoine**.

B. 2ème idée. La société est une source de financement qui dépasse largement les possibilités d'un seul individu :

Les entreprises, commerciales et industrielles, ont besoin de capitaux en fonction de leur taille. Ainsi, la société par actions notamment la SA, peut inviter les actionnaires et les tiers à souscrire à une augmentation de capital ; elle peut solliciter les épargnants pour qu'ils lui prêtent de l'argent dans le cadre d'un emprunt obligataire contre versement d'un intérêt annuel (art.228-95 C.com).

La société par actions permet également la constitution de puissants groupes dont certains auront vocation à dominer l'économie mondiale (société mère et filiales) : holding.

C. 3ème idée. La société est une technique de limitation des risques, par la séparation des patrimoines

La création d'une société présente de nombreux avantages, deux principaux :

1. 1er avantage : La protection relative des patrimoines

En principe, l'entrepreneur engage tous ses biens. C'est pourquoi, la loi sur l'initiative économique (du 01.08.2003) et la loi sur la modernisation de l'économie (LME, du 04 août 2008) **rendent insaisissables sa résidence principale et tous ses biens fonciers bâtis ou non s'ils ne sont pas affectés à un usage professionnel**.

Depuis une loi du 15 juin 2010, l'entrepreneur peut créer deux patrimoines séparés : un patrimoine privé, et un patrimoine professionnel appelé patrimoine affecté. Il est composé de l'actif consacré à l'activité de l'entreprise, celui-ci étant le seul gage des créanciers professionnels. C'est ce qu'on appelle l'EIRL.

Par ailleurs, l'entrepreneur individuel aurait intérêt à mettre son entreprise individuelle en société où sa responsabilité est limitée à son apport. C'est le principe de l'autonomie du patrimoine qui prévaut ici. Tout ceci est théorique !

En pratique, la séparation des patrimoines n'est pas toujours efficace. Elle peut être contournée notamment par le recours des banques au contrat de cautionnement dont l'exécution par les dirigeants ou associés engage leur patrimoine personnel.

2. 2ème avantage : La société est une technique de transmission de l'entreprise pour cause de mort et entre vifs

Le décès de l'entrepreneur individuel entraîne souvent la disparition de l'entreprise qui tombe en indivision dont la gestion est difficile à organiser. Au contraire, la société permet d'assurer la croissance et

la pérennité de l'entreprise dans la mesure où ce sont les actions ou les parts (les titres) et non l'entreprise qui appartiennent aux héritiers co-indivisaires**.**

La transmission de l'entreprise est également plus facile lorsqu'elle est exploitée sous forme sociétaire, entre vifs, surtout lorsque les dirigeants, proches de la retraite, souhaitent passer la main à leurs enfants ou à des tiers repreneurs. La cession d'actions ou de parts sociales s'opère à des conditions fiscales souvent avantageuses**.**

1-Les cessions d'actions s'opèrent au taux de 0,10 %**.**

2- La cession de parts de SARL est en revanche plus coûteuse. Elle est soumise au taux de 3% après un abattement de 23000€ rapporté au pourcentage de titres cédés.

Or, la cession d'une entreprise individuelle est imposée aux taux progressifs en fonction des fractions de valeur :

- de 0 à 23000 € : 0 %

- entre 23000 € et et 200 000€: 3 %

- Au-delà de 200 000€ : 5%.

Voilà pour la technique de transmission et pour le deuxième motif.

§ 3. 3ème motif : La recherche des avantages fiscaux et sociaux : statut des dirigeants, des associés et des salariés.

Il s'agit de règles qui sont propres au droit français. Nous ne les développerons pas ici

Dans l'entreprise individuelle, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu (*IR*) à des taux progressifs. Ces taux varient entre 0% et 45%. Il existe 5 tranches pour 2015:

- jusqu'à 9 690 € : 0%
- de 9 691 à 26 764 € : 14,00%
- de 26 765 à 71 754 € : 30,00%
- de 71 755 à 151 956 € : 41,00%
- au-delà de 151 956 €: 45%

Mais l'entrepreneur peut adhérer à un Centre de gestion agréé et bénéficier de certains abattements fiscaux.

Dans l'entreprise exploitée sous forme de société, le régime fiscal varie suivant le type de société adopté.

Deux situations sont à distinguer :

Les sociétés de personnes, dites sociétés transparentes sont des sociétés à risque illimité dans lesquelles les associés engagent indéfiniment leur responsabilité. Elles sont soumises à l'IR

Elles ont le même statut fiscal que l'entreprise individuelle (l'IR : 5 tranches). Cependant, elles peuvent opter pour le régime de l'IS.

Les sociétés de capitaux, dites sociétés opaques sont des sociétés à risque limité dans lesquelles les associés engagent leur responsabilité à hauteur de leurs apports**.**

Les bénéfices sont imposés dans les mains de la société au taux normal de 33,33 % (IS).

Il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 15,5%

B. Les intérêts sociaux de la création de société ou de la mise en société d'une entreprise individuelle

La société offre aux salariés un certain nombre de **droits** dont principalement **la participation aux résultats (1), au capital (2) et à la gestion (3)**. Elle offre également **un statut social avantageux aux dirigeants (4)**.

1. La participation aux résultats

La participation aux résultats prend deux formes :

L'accord de participation : Il permet aux salariés de se voir attribuer une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise.

L'accord d'intéressement :

Il permet aux salariés de bénéficier financièrement des performances de leur entreprise.

2. La participation au capital

Elle a trois régimes :

Le premier régime : L'option de souscription ou d'achat d'actions, sur le modèle américain des *stock options***.**

Le deuxième régime : **c'est le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise**.

<u>Le troisième régime :</u> c'est le régime des plans d'épargne salariale. Le plus important est le plan d'épargne d'entreprise (PEE).

<u>3. La participation à la gestion</u>

Il existe deux régimes:

L'un est obligatoire dans les sociétés dotées d'un comité d'entreprise (50 salariés): deux délégués (un cadre et un ouvrier) siègent au conseil d'administration (donc SA) avec voix consultative (Articles 2323-62 à 2323-7 C.tr. Ancien 432-6 C.tr. et s.).

La loi du 14 juin 2013 prévoit la participation de représentants des salariés, avec voix délibérative, aux conseils d'administration (ou de surveillance) des grandes entreprises. Les sociétés concernées sont celles dont les effectifs totaux sont au moins égaux à 10 000 salariés dans le monde ou à 5 000 en France.

L'autre est exceptionnel, facultatif. On est en présence de véritables administrateurs (4 au maximum, 5 dans les sociétés cotées et jamais au-delà du tiers du CA) ayant voix délibérative et bénéficiant de garanties spécifiques (licenciement difficile, révocation *ad nutum* exclue, ...).

<u>4. Le statut de salarié des dirigeants !</u>

Tous les dirigeants sociaux n'ont pas le statut de salariés. Ils ne bénéficient pas tous du régime général de la sécurité sociale ni d'une bonne retraite. C'est le cas de l'entrepreneur individuel et du gérant majoritaire. Ils ne bénéficient pas non plus de la protection

contre le chômage, sauf à avoir un contrat de travail avec la société (art.225-22 C.com).

Section 2. Le classement des sociétés

Six catégories de distinctions ou de comparaisons :

A/- Les sociétés civiles et les sociétés commerciales

Les sociétés civiles ne peuvent effectuer que des opérations de caractère civil. Elles sont donc civiles par l'objet : les activités libérales (* *SCP, SCM, SPFPL* *), l'agriculture (* *GAEC, GAF* *), la construction immobilière, l'activité d'enseignement, …

Les sociétés commerciales accomplissent des actes de commerce c'est-à-dire des actes d'intermédiaire. La plupart sont dotées de la personnalité morale.

En vertu de l'art. 210-1 C.Com. :

«*Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet, les SNC, les SCS, les SARL et les sociétés par actions*».

Cet article est générateur de conflits entre la forme et l'objet.

En effet, jamais une société à objet civil ne pourra être considérée comme civile si elle emprunte la forme d'une société commerciale. Il en va ainsi des sociétés d'exercice libéral (SEL : SELARL, SELARLU, SELAFA, SELCA, SELAS, SELASU).

Les sociétés commerciales relèvent du Tribunal de Commerce. Les sociétés civiles relèvent du TGI.

Dans les sociétés commerciales, la preuve est libre. Dans les sociétés civiles, c'est la preuve par écrit pour les actes ayant une valeur supérieure à 1500€.

Les sociétés civiles sont soumises à l'IR. Les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés de personnes, sont soumises à l'IS.

B/ - Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Les sociétés de personnes sont dominées par l'*intuitus personae* et par l'aspect contractuel. Elles sont composées d'associés qui se connaissent et se font confiance. C'est pourquoi, les parts sociales ne sont cessibles qu'avec le consentement de tous les autres associés. Le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met en principe fin à la société, sauf clause statutaire contraire.

Les associés sont indéfiniment tenus des dettes sociales.

S'ils sont commerçants, ils sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales.

On qualifie les sociétés de personnes, de sociétés fermées : Ex : La SNC, la SCS, les sociétés civiles, les sociétés en participation, les sociétés créées de fait. Tout le monde participe à l'exercice du pouvoir sauf stipulation contraire.

Les sociétés de capitaux ou par actions sont dominées par les capitaux apportés en dehors de toute considération de la personne. Les actionnaires ne se connaissent pas et l'exercice du pouvoir est fortement organisé et hiérarchisé.

Chaque associé n'est tenu du passif que dans la limite de son apport et les titres qu'il reçoit en contrepartie sont librement négociables et cessibles sauf clauses statutaires d'agrément ou de préemption.

C'est la forme sociale réservée en principe aux affaires de grande dimension. L'exemple type c'est la société anonyme.

S'agissant de la société par actions simplifiée pluripersonnelle ou unipersonnelle (SAS art.227-1 et s.C.Com.), elle échappe au formalisme pesant sur la SA, mais c'est une société de capitaux. La SAS est davantage dominée par une très grande liberté contractuelle. Elle est destinée aux petites, moyennes et grandes entreprises, mais aussi à promouvoir la création de filiales communes.

Elle n'est pas tenue d'avoir un capital minimum et les associés peuvent y faire des apports en industrie.

Enfin, en ce qui concerne la SARL, c'est une société hybride, mixte. Elle est une société de personnes en raison du fort *intuitus personae* qui caractérise son fonctionnement notamment la cessibilité des parts sociales.

Elle est relativement fermée aux tiers étrangers et peut être fermée statutairement à la famille et aux autres associés.

La SARL ressemble en revanche à une petite société de capitaux parce que les associés ne sont responsables que dans la limite de leurs apports. Ses différents organes s'apparentent davantage à ceux des sociétés par actions que des sociétés de personnes.

C/ - Les sociétés faisant ou non une offre au public de titres financiers

Les sociétés qui peuvent avoir recours à une offre au public de titres financiers sont :

- Les sociétés civiles de placement immobilier (L. 31.12.1970).
- Les sociétés par actions, notamment les SA et les SCA ayant un capital minimum de 37000 € **(Art. 224-2 C.Com.)**.

Ces sociétés sont soumises à un formalisme de constitution lourd ; elles sont tenues à des mesures de publicité très complètes destinées à informer les actionnaires et à protéger les épargnants.

Elles sont soumises également au contrôle strict de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) notamment lorsque leurs titres sont cotés en bourse.

Ce mode de constitution et de fonctionnement est réservé aux sociétés de grandes dimensions qui pèsent économiquement très lourd.

D/ - Les sociétés avec ou sans personnalité morale

Le principe est que dès lors qu'elles sont immatriculées au RCS, les sociétés sont dotées de la personnalité morale.

Les sociétés en participation et les sociétés créées de fait constituent les exceptions à ce principe. Elles sont sans personnalité morale en raison du fait qu'elles ne sont pas immatriculées.

La société en participation (SEP) (Art. 1871 et s. C. civ.). C'est la société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité légale.

La société créée de fait se rencontre lorsque des personnes ont en fait adopté entre elles et à l'égard des tiers, un véritable comportement d'associés, sans avoir passé un contrat de société.

Exemple:

La concubine qui participe à l'entreprise de son concubin non seulement en mettant en commun des biens inhérents à la vie maritale, mais en adoptant un comportement qui révèle l'intention de s'associer avec son concubin et en réunissant tous les éléments constitutifs du contrat de société.

E/ - Les sociétés de droit privé et les sociétés de droit public

L'intervention de l'Etat dans l'économie est une caractéristique traditionnelle en France depuis Colbert. D'où la notion d'entreprise publique.

Malgré la politique de privatisation déclenchée par le président Jacques Chirac en 1986, il subsiste un certain nombre d'entreprises publiques sous formes de sociétés :

1 – Les Sociétés Nationales où l'Etat détient tout le capital et où il est représenté au sein du CA avec les salariés et des personnalités compétentes.

2 – Les sociétés où l'Etat détient une participation majoritaire ou minoritaire.

F/ - Les sociétés de droit commun et les sociétés à statut spécial

Certaines sociétés ont une vocation générale et sont régies par le Code de commerce et par les articles du Code civil sur les sociétés. On les appelle sociétés - types : SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS, Société en participation et société créée de fait.

D'autres sociétés, de plus en plus nombreuses, sont créées à partir des sociétés – types, pour répondre à des besoins spécifiques: les SEL, les SPFPL, les GAEC, les SDR, les sociétés civiles, les SEM, les sociétés d'économie mixte à opération unique...

Voilà pour le classement.

Section III : Les sources contemporaines du droit des sociétés

§ 1- Le Code de commerce

La loi d'origine est la loi du 24 juillet 1966. Elle a été intégrée au Code de commerce en 2000 (art. L. 210-1 à 960-1). Elle ne traitait que des principes fondamentaux des obligations commerciales. Les autres dispositions étaient contenues dans le décret d'application du 23 mars 1967. Lui aussi a été intégré dans le Code de commerce (art. R. 201-1 à 252-1) qui connaît tous les ans ou presque de nombreuses modifications.

Les nouveaux textes sont très méticuleux, laissent peu de place à la volonté individuelle et, sur le fond, apportent peu d'innovations.

§ 2- Le rôle de la jurisprudence et de la doctrine

La jurisprudence joue un rôle essentiel dans la construction du droit des sociétés. Les juges n'hésitent pas à solliciter quelques textes très généraux pour fonder des solutions importantes, par exemple pour sanctionner l'abus de droit (Art. 1382), et pour nommer des administrateurs provisoires, pour engager la responsabilité des dirigeants,… sur le fondement de l'intérêt social.

Quant à la doctrine, son apport est aussi essentiel que la jurisprudence et les autres sources. Exemples : ouvrages, colloques, articles, études…

§ 3- L'influence du droit de l'Union Européenne

L'art. 54 du Traité de Rome pose le principe de la libre concurrence ; il postule la coordination des garanties qui sont exigées des sociétés, dans les Etats membres.

Ainsi, plusieurs directives (14) ont déjà vu le jour entraînant de nombreuses modifications de la loi française. L'influence s'opère dans les deux sens : Du Droit de l'UE vers le Droit français et inversement. Les articles 49 et 54 du TFUE consacrent la liberté d'établissement pour les sociétés commerciales constituées dans les Etats membres de l'UE.

Plusieurs formes sociétaires ont été créées :

1- La SE (Société Européenne).

2- La SCE (société coopérative européenne).

3- Le projet de Société Privée Européenne (SPE). Elle n'est pas encore adoptée.

4- Enfin, en matière de fusions transfrontalières, une loi du 03 juillet 2008 a transposé la directive n° 2005/56/CE du 26 octobre 2005. Ore adoptée.

LEÇON I

LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

CHAPITRE I - LES REGLES DE CONSTITUTION

SECTION I - LES REGLES COMMUNES (OU GENERALES) A TOUS LES CONTRATS

S-II : Les règles spécifiques

S-III : Les sanctions des règles de constitution

Quatre conditions sont essentielles à la validité de ce contrat, en application de l'art. 1108 C. civ. Elles concernent le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

SOUS-SECTION I - LE CONSENTEMENT DES ASSOCIES

Il doit être intègre et sincère.

§ 1- L'intégrité du consentement : absence de vice

Le consentement doit exister.

Il doit être exempt de vice. Il y a 3 vices : L'erreur pourrait porter sur la personne d'un associé ou sur la nature du contrat conclu ou sur le type de société adopté. Le dol consiste dans des manœuvres

frauduleuses ou dans un silence mensonger de l'un des associés, sans lesquels l'autre associé n'aurait pas contracté (Art. 1116 C. civ ; Cass. Com. 4 juin 1985, Bull. Joly 1985.787). Enfin, le vice de violence est très exceptionnel. Il prend la forme d'un état de nécessité pouvant être assimilée à la force majeure.

§ 2- La sincérité du consentement : absence de simulation

La volonté de s'associer doit être sincère. Elle ne doit pas être simulée. Il y aurait simulation si le contrat de société (* *acte apparent* *) dissimulait une autre convention (* *secrète* *) voulue en réalité par les parties, par ex. le contrat de société dissimule un contrat de prêt, de travail, de vente, ou de donation. La simulation peut porter soit sur la nature du contrat, soit sur l'existence même du contrat, soit sur la personne des associés.

Quant aux effets de la simulation, entre les parties, c'est l'acte secret qui l'emporte, à condition qu'il soit lui-même licite. Si l'acte secret est nul, le contrat de société est le seul à produire effet dès lors qu'il est valable.

SOUS-SECTION II - LA CAPACITE DES ASSOCIES

La capacité est l'aptitude à posséder et à exercer l'ensemble de droits subjectifs reconnus à la personne. Elle varie suivant le type de société et la qualité de l'associé.

§.1- La capacité des mineurs

Les sociétés dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçant, sont fermées aux mineurs non émancipés et aux

incapables majeurs sous tutelle ou curatelle parce qu'ils n'ont pas la capacité commerciale (Art. 121-2 C. com. et 478 C.civ.). Il en va ainsi des SNC, des SCS et des SCA pour les commandités. Depuis la loi du 15 juin 2010, ces sociétés sont ouvertes au mineur émancipé à condition que le juge des tutelles lui donne l'autorisation d'être commerçant.

En revanche, le mineur, même non émancipé, peut être actionnaire d'une SA ou associé d'une SARL, dans la mesure où la capacité commerciale n'est pas exigée dans ces sociétés, à condition de respecter la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et des mineurs.

§.2- La capacité des époux

Deux époux peuvent être, seuls ou avec des tiers, associés dans une société, quelle qu'en soit la forme, et participer ensemble ou non à la gestion sociale (Art. 1832-1 C. civ. et 1421 : c'est le principe de la gestion concurrente). Ils peuvent l'être même s'ils souscrivent au capital l'un et ou l'autre avec des biens de la communauté, sous deux réserves :

1/ Le conjoint apporteur doit informer l'autre conjoint en cas d'apport de certains biens (* *deniers communs* *). L'objectif est de permettre à l'époux non apporteur de revendiquer sa qualité d'associé pour la moitié des parts dans les SARL (art. 1832-2 C.civ).

2/ Le conjoint apporteur doit informer l'autre conjoint et doit obtenir son consentement, en cas d'apport d'autres catégories de biens (*

fonds de commerce, immeubles *). A défaut, l'apport sera nul (Art. 1832-2 C. civ. Art. 1424 et 1425 et 1427 C. civ.).

Dans les SA, seul le conjoint apporteur aura la qualité d'actionnaire.

Un bien commun nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle d'un époux ne peut être apporté que par celui-ci.

Un bien propre à un conjoint reste la propriété de son titulaire qui peut en disposer librement.Les conjoints de dirigeants qui participent régulièrement à l'activité de l'entreprise sont tenus d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié. L'option pour l'un de ces statuts permet notamment au conjoint d'améliorer sa protection sociale au titre de sa retraite.

N.B. S'agissant de la capacité des partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS), (articles 515-1 à 515-7 C.civ.), ils peuvent, seuls ou avec d'autres, être associés d'une société commerciale. Leur situation est proche de celle des époux mariés sous le régime de séparation des biens sauf convention contraire.

§.3- La capacité des étrangers

L'exercice d'un commerce par un étranger ou l'acquisition de la qualité d'associé est soumise à une autorisation délivrée par la préfecture du lieu de résidence de la personne de nationalité étrangère, dans le département dans lequel cette dernière envisage d'exercer pour la première fois son activité (art. 122-1 et s. C.com).

Toutefois, les ressortissants des pays membres de l'UE et les titulaires d'une carte de résident sont dispensés de l'autorisation préfectorale. Il en va de même des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention internationale prévoyant cette dispense.

§.4- La capacité des personnes morales

Les sociétés de droit privé dotées de la personnalité morale peuvent souscrire des actions ou des parts sociales d'autres sociétés. Elles doivent respecter les règles relatives à l'obligation d'information et aux participations.

Concernant les personnes morales de droit public, l'Etat peut souscrire au capital d'une société quelconque. Une loi est nécessaire si l'Etat entend soit acquérir la majorité du capital social soit nationaliser la société.

Les collectivités territoriales (* *régions, départements, communes* *) ne peuvent avoir la qualité d'associé que dans des sociétés ayant pour objet l'exploitation de services publics locaux ou l'exercice d'activités d'intérêt général, sauf autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat.

SOUS-SECTION III : L'OBJET (SOCIAL)

§.1- La définition de l'objet social

En vertu de l'art. 1832 C. civ., l'objet du contrat de société est le genre d'activité que la société se propose d'exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. Il doit être déterminé dans les statuts.

Il correspond au programme que la société s'est fixé. Il se distingue de l'activité sociale qui est réellement exercée par la société. C'est cette activité qui devra être prise en considération en cas de conflit avec l'objet social statutaire, notamment pour apprécier sa licéité (de l'activité).

§.2- Les intérêts pratiques liés à l'objet social

1- L'objet social permet de délimiter l'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux. C'est un critère d'identification des dépassements de l'objet social et des abus pouvant être commis par les dirigeants.

2- L'objet social permet de déterminer le régime de chaque type de société et de dire si elle est civile ou commerciale, lorsque la forme ne dicte pas cette solution.

3- La réalisation ou l'extinction de l'objet social entraîne en principe la dissolution de la société, sauf clause statutaire contraire ou modification des statuts par décision des associés.

§.3- Les qualités requises de l'objet social

Deux qualités principales :

1- L'objet social doit être possible et déterminé ; il ne doit être ni trop vague, universel, fourre-tout, ni trop rigide.

2- L'objet social doit être licite et donc conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Art. 6 et 1833 C. civ.).

Exemples :

- l'exploitation d'une maison close : activité illicite

- exploitation par un avocat d'un night club,... : Cette activité est contraire à la dignité de l'avocat.

La société illicite est frappée d'une nullité absolue ; elle peut être constitutive d'une infraction pénale.

SOUS-SECTION IV : LA CAUSE DU CONTRAT DE SOCIETE

§.1 – L'exigence d'une cause effective

La cause du contrat de société est la raison pour laquelle (* *le pourquoi ?* *) deux ou plusieurs personnes s'associent. Elle est souvent confondue avec l'objet social dans la mesure où la raison d'être de la société est précisément la réalisation de cet objet.

Le contrat de société doit avoir une cause effective. Le défaut de cause est exceptionnel.

§.2 – L'exigence d'une cause licite

La société qui a une cause illicite ne peut avoir aucun effet, comme toute obligation illicite (art.1131 C.civ.). Les cas d'illicéité sont nombreux. En voilà quelques exemples où les sociétés sont constituées pour des motifs frauduleux :

1- Un époux qui exploitait un fonds de commerce constitutif de bien commun avait réalisé une fraude aux droits de sa femme en constituant avec trois associés une SARL à laquelle il avait confié la location-gérance de ce fonds, moyennant une faible redevance. (Arrêt Demuth 28.1.92. JCP 92.II.21756, Bull. Joly 92, p. 419).

2- L'apport d'une propriété à une société d'exploitation viticole, en vue seulement de soustraire ce bien à une prochaine saisie du débiteur (* *propriétaire* *).

L'objectif ici est de faire échec au droit déterminé d'un tiers : les héritiers, les créanciers ou le fisc par exemple.

Dans tous les cas, la fraude doit être prouvée. Elle est sanctionnée par la nullité.

SECTION II – LES REGLES PROPRES (SPECIFIQUES) AU CONTRAT DE SOCIETE

SOUS--SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS (OU CARACTERISTIQUES) DU CONTRAT DE SOCIETE (DE FOND)

S-S II : Les conditions de forme et de publicité.

Rapidement : En partant de l'art. 1832 C. civ., les associés doivent s'entendre sur quatre éléments caractéristiques, mise à part l'objet social, pour constituer valablement une société :

1/ le nombre des associés

2/ la mise en commun d'apports

3/ la participation aux résultats

4/ l'*affectio societatis*.

§.1 – La pluralité d'associés

Le nombre d'associés varie selon la forme sociétaire :

- Deux associés suffisent pour créer une SARL classique pluripersonnelle ou une SNC. C'est le minimum. Cependant, un associé unique suffit dans l'EARLU, L'EURL, la SASU.

- La SARL ne peut comprendre plus de 100 associés (Ord. 25.3.2004). C'est le maximum (* *10 dans les EARL* : art. 324-1 C.rural*).(Art. 223-3 C. com).

- Dans les SA, le nombre minimum est de 7 actionnaires et le nombre maximum peut atteindre des milliers voire des millions d'actionnaires.

- Dans une société en Commandite simple ou par actions : il faut au moins un associé commandité, 1 associé commanditaire dans les SCS et 3 associés commanditaires dans les SCA.

La pluralité d'associés n'exclut pas l'hypothèse de société fictive ou de façade.

Le nombre minimum et le nombre maximum, lorsqu'ils sont prévus par les textes, doivent être respectés tout au long de la vie sociale. Cependant, les associés peuvent décider de transformer la société, de céder des titres à des tiers ou de racheter des titres à d'autres associés, afin de respecter le nombre minimum. Il en va de même en cas de décès de plusieurs associés.

§.2 – La mise en commun d'apports

La nécessité des apports. La diversité des apports. La réunion des apports : le capital social.

A/- La nécessité des apports

Partir toujours de l'art. 1832 C.civ..

L'apport désigne d'une part, l'opération par laquelle l'associé affecte certains biens ou services à la société qu'il constitue, d'autre part, la

représentation de chaque bien ou service, c'est-à-dire les valeurs mises à la disposition de la société : somme d'argent, immeuble, fonds de commerce, brevet,... Seule la fourniture d'un véritable apport permet d'attribuer la qualité d'associé.

L'apport est aussi une manifestation de l'*affectio societatis*. C'est également un mode de financement de l'entreprise et doit donc avoir une valeur pécuniaire. Par conséquent, l'absence d'apport, ou un apport fictif, peut entraîner la nullité de la société (brevet périmé, bien grevé d'un passif supérieur à sa valeur brute, … Art. 1844-10 al. 1 C. civ. et 1832 C. civ.).

En contrepartie de l'apport qu'il réalise, tout associé est rémunéré par l'attribution proportionnelle de parts sociales ou d'actions.

B/- La diversité des apports

L'art. 1843-3 C. civ. distingue trois catégories d'apports : en numéraire, en nature, en industrie.

1 – L'apport en numéraire

C'est l'apport d'une somme d'argent : en espèces, par chèque, par virement ou par compensation avec une créance.

C'est l'apport le plus simple et le plus fréquent.

On distingue la souscription de la libération. La souscription est la promesse de réaliser l'apport ; la libération est l'exécution de cette promesse par le versement effectif des fonds.

La souscription doit être intégrale à la constitution dans toutes les sociétés. La libération peut être fractionnée. Elle doit être d'au moins

un cinquième du montant des parts représentant des apports en numéraire dans les SARL (Art 223-7 C. com. issu de la loi NRE). Elle est de moitié au minimum dans les SA (Art. 225-3 C. com.). Le surplus doit être libéré dans les SARL et dans les SA., dans un délai de 5 ans, sauf disposition statutaire contraire.

L'apporteur qui ne verse pas les fonds à l'échéance (qui ne tient pas sa promesse) devient de plein droit débiteur des intérêts de la somme due au taux légal ou statutaire. Il peut même être condamné à des dommages et intérêts si la société subit un préjudice.

L'associé qui ne respecte pas ses obligations c'est-à-dire qui ne libère pas le montant de ses actions ou parts sociales s'expose à l'exclusion par vente forcée et publique de ses titres.

2 – Les apports en nature

Il s'agit d'apport de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels : fonds de commerce, brevets d'invention, clientèles commerciales ou civiles dès lors qu'ils sont transférables et évaluables.

L'apport en nature peut être réalisé de trois manières : en propriété, en jouissance ou en usufruit.

a) - L'apport en propriété

Il se réalise par le transfert à la société de la propriété du bien et, par sa mise effective à la disposition de la société (Art 1843-3 al. 2 C. civ.). Il est assimilé à la vente. L'apporteur est tenu de garantir la société contre toute éviction et contre les vices cachés (* *comme un vendeur*.

Le transfert de propriété n'intervient qu'au jour où la société est immatriculée au RCS. A partir de cette date, la société aura un patrimoine propre et supportera seule les conséquences de la perte ou de la détérioration des biens apportés.

L'apport revêt un caractère aléatoire, puisque l'apporteur reçoit des parts sociales ou des actions dont la valeur variera en fonction des résultats de l'exploitation sociale (* *bénéfices ou pertes: dividendes ou contribution au passif*

L'évaluation de l'apport en nature doit être la plus exacte possible que ce soit au moment de la formation de la société ou en cours de vie sociale, dans l'intérêt des créanciers mais aussi des associés : deux dangers peuvent intervenir :

1/ Une sous-évaluation ou une surévaluation de l'apport romprait l'équilibre dans la répartition des droits sociaux : moins ou plus de droits sociaux, moins ou plus de droits d'enregistrement.

2/ Une surévaluation créerait une apparence trompeuse de solvabilité nuisible à la garantie de paiement qu'offre le capital social aux tiers.

En cas de surévaluation frauduleuse manifeste, la responsabilité pénale de tous ceux qui y ont contribué peut être engagée (Art. 241-3 C. Com. : associés, dirigeants, CAA…)

Ces deux dangers portent peu de préjudice dans les sociétés à risques illimités où tous les associés sont responsables du passif.

En revanche, ces deux dangers sont réels dans les sociétés à risques limités où il est instauré un contrôle préalable de l'évaluation réalisé par un commissaire aux apports (CAA), désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires ou, à défaut, par décision de justice (art.

223-33 et 225-8- et -147 : Décret du 8 septembre 2014). Mais cette procédure peut être écartée dans les SARL, sous trois conditions cumulatives :

1- Lorsqu'aucun apport en nature n'excède 30 000€ (article D. 223-6-1)

Et

2- lorsque l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation du CAA ont une valeur inférieure à la moitié du capital social (Art. L. 223-9, 223-33, 225-8 et 225-101 C. com. et art. R. 223-6-1).

3- à l'unanimité des associés.

b) - L'apport en jouissance

L'apporteur en jouissance met son bien, comme un bailleur, à la disposition de la société. Elle peut l'utiliser librement mais elle ne peut en disposer. (Art. 1843-3 al. 4 C. civ.). C'est un droit personnel. Ce type d'apport n'opère pas transfert de propriété. Il échappe à l'action des créanciers de la société. L'apporteur en jouissance a l'assurance de récupérer son bien à la dissolution ; il doit l'entretenir et permettre à la société d'en jouir paisiblement.

c) - L'apport en usufruit

Il ne peut avoir lieu que si le propriétaire d'un bien accepte de le démembrer en usufruit et en nue-propriété. L'apport en usufruit réalise un transfert de droit réel au profit de la société. Celle-ci peut en user (* *usus* *) et en tirer profit (* *fructus* *) mais elle ne peut en disposer (* *abusus* *). L'associé apporteur conserve la nue-propriété

du bien dont la société n'a que l'usufruit et ce, jusqu'au décès de l'apporteur ou jusqu'au terme prévu (* *délai maximum de 30 ans* *). (Art. 617 et 619 C. civ.). Mais l'inverse est possible: l'apporteur garde l'usufruit et la société la nue-propriété.

3 - L'apport en industrie

C'est un engagement pris par un associé de mettre à la disposition de la société tout ou partie de son activité (* *styliste, maître de chai, du « nez » dans le parfum, …* *) : ses connaissances techniques, ses services, son savoir-faire professionnel, son expérience, sa notoriété, son influence et plus généralement son travail en dehors de tout lien de subordination (* *sinon requalification en contrat de travail* *).

Ce type d'apport est rarissime (* *on préfère les contrats de travail et de collaboration* *) et difficile à évaluer. Il ne concourt pas à la formation du capital social. C'est pourquoi il est prohibé dans les sociétés par actions (* *sauf SCS et SCA pour les commandités* *). Il est expressément autorisé en faveur de tous les associés dans les SARL et (depuis 2008 LME) dans les SAS. Les statuts fixeront librement les modalités de souscription et de répartition des parts et actions d'industrie, ainsi que le délai au terme duquel ces actions et ces parts font l'objet d'une évaluation

L'apport en industrie donne lieu à l'attribution de parts sociales. Ces parts sont égales à celles de l'associé qui a le moins apporté en numéraire ou en nature, sauf clause statutaire contraire. (Art. 1844-1 et 1843-2 C. civ.). Les apporteurs en industrie jouissent des mêmes droits politiques et financiers que les autres associés.

L'apporteur en industrie ne peut exercer une activité concurrente à celle qu'il a promise à la société.

Ses droits sont incessibles et intransmissibles (* *en cas de décès* *). C'est un travail personnel.

C/ - La réunion des apports (en dehors de l'apport en industrie): le capital social

Le capital social est l'ensemble des valeurs apportées par les associés.

Toute société devrait disposer d'un capital dont un montant minimum est parfois exigé par les textes. Dans les sociétés anonymes, il s'élève à 37000 €.

Le montant du capital social dans les SARL et dans les SAS est fixé par les statuts.

Les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, peuvent se contenter d'un capital peu élevé ou même symbolique ou encore sans capital.

La nécessité d'un capital résulte d'une exigence juridique puisqu'il constitue l'une des mentions obligatoires des statuts (art. 1835 C. civ.).

Quelles sont les fonctions du capital social ?

1- Le capital social sert à acquérir des éléments d'actif. **Il se présente comme un instrument de financement de l'activité sociale.**

2- Il permet aussi de préciser l'étendue de la responsabilité des associés d'une part, et les garanties des créanciers d'autre part.

3- Le capital permet de déterminer les droits et obligations de chacun des associés. Il s'ensuit que l'associé qui détient la majorité du capital exerce le contrôle de la société.

En principe, le capital social est intangible : il ne peut être modifié sans l'accord de la collectivité des associés.

C'est pourquoi, les opérations d'augmentation et de réduction du capital social font l'objet d'une réglementation très stricte qui vise à informer les tiers et à assurer l'égalité des associés.

Il est interdit aux associés de distribuer une partie du capital social, sous forme de dividendes.

Voilà pour la mise en commun d'apports (c'est le deuxième élément constitutif du contrat de société).

§.3 - La participation aux résultats

La participation aux résultats de l'exploitation est un élément constitutif du contrat de société qui se situe au cœur de l'article 1832 c. civ. L'essence même de ce contrat est la participation aux résultats de l'exploitation.

A la clôture de chaque exercice, il convient de mesurer le résultat, de chercher s'il est bon ou mauvais, si l'entreprise a gagné de l'argent ou si elle en a perdu, si elle a dégagé un bénéfice et réalisé des économies ou si elle a subi une perte. Le résultat est donné par la formule suivante :

Résultat = Produits – Charges

A/ - La recherche de bénéfices ou d'économies

La réalisation d'économies par la société peut porter sur des avantages moraux et/ou matériels à caractère accessoire : achats de marchandises ou de matériels à moindres frais, services communs divers,…Elle ne soulève pas de difficulté particulière pour la détermination des droits individuels des associés. Chaque associé profite automatiquement de l'allégement de ses frais généraux en raison de la prise en charge par la société de certaines activités.

Il en va autrement des bénéfices distribuables. Leur répartition, s'il en existe, suppose une réunion en assemblée des associés afin de se prononcer sur l'affectation des bénéfices réalisés. Cependant, l'existence de bénéfices distribuables n'implique pas qu'il y ait nécessairement distribution.

Dès lors, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

1- La première solution consiste à distribuer intégralement les bénéfices.

2- La deuxième solution réside dans la mise en réserve des bénéfices sociaux (* *réserve légale, réserve statutaire, réserve libre* Art. 232-10 et 11 C.com*). Cette stratégie est destinée à favoriser l'autofinancement de tout ou partie des investissements et à prévenir un avenir difficile.

3- La solution intermédiaire, probablement la meilleure, consiste à combiner les deux opérations précédentes.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net après apurement des pertes antérieures et réalisation des prélèvements obligatoires.

B/ - La contribution aux pertes

La contribution aux pertes est la contrepartie de la participation des associés aux bénéfices ou à l'économie réalisée (art. 1832 al. 3 C.civ.).

L'obligation aux pertes concerne les rapports entre associés. La contribution de chaque associé aux pertes se déterminera à la liquidation de la société ou lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. En principe, chacun contribue aux pertes proportionnellement à la part de capital qu'il détient dans la société ; mais une répartition inégalitaire est admise, dès lors qu'elle n'est pas léonine ou exorbitante (art. 1844-1 C.civ.).

C/- La prohibition (l'interdiction) des clauses léonines

La clause léonine est une clause exorbitante, excessive qui procure un avantage disproportionné à certains associés par rapport à d'autres.

Certaines inégalités sont permises, d'autres ne le sont pas.

En effet, le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux et inversement. Un apporteur en industrie peut être mieux rémunéré que l'associé qui a le moins apporté en numéraire ou en nature (art. 1844-1 al. 1er C. civ.). Ces clauses sont valables dès lors qu'il subsiste pour les autres associés un espoir de profit et un risque.

En revanche, la clause qui attribuerait à un associé la totalité du profit réalisé par la société est interdite. C'est une clause léonine (art. 1844-1 al. 2 C. civ.). Cette attribution de « la part du lion » serait la négation de la société. Une clause qui exclurait totalement du profit ou des pertes un associé est également léonine. Il en va de même de la clause qui mettrait à la charge de l'un d'eux la totalité des pertes (art. 1844-1 al.2 C. civ.).

La présence d'une clause léonine dans les statuts n'entraîne pas la nullité de la société. La clause est simplement réputée non écrite (art. 1844-1 al. 2 C ; civ. ; art. 235-1 C. com.).

Voilà pour la participation aux résultats (troisième élément constitutif du contrat de société)

§.4 - L'affectio societatis (ou élément intentionnel)

C'est un élément de nature psychologique (* *moral* *) nécessaire à la validité de toute société. Il est utile non seulement à la naissance de la société mais se manifeste et doit se manifester tout au long de la vie sociale. Sa disparition constituerait une menace de dissolution de la société.

Cette notion exprime la volonté du moins implicite de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité, en vue de la réalisation de l'objet social.

Cette notion est très présente et forte dans les sociétés à risque illimité. A l'opposé, elle n'a presque aucune signification dans les sociétés par actions de dimensions importantes.

N.B. Un associé majoritaire qui cède une partie de ses titres à un nouvel associé ne peut pas faire annuler la cession en faisant valoir que celui-ci n'est pas animé de la volonté de s'associer (Cass. com. 11 juin 2013).

Quelles sont les fonctions de l'affectio societatis ?

1- L'*affectio societatis* révèle l'existence ou l'inexistence de la société notamment lorsque celle-ci n'est pas immatriculée au RCS.

S'il s'agit d'établir qu'une société est fictive, il suffit de démontrer l'absence d'*affectio societatis*.

S'il s'agit de démontrer la disparition de l'affectio societatis en cours de vie sociale, il convient de mettre en évidence un profond désaccord entre associés.

2- L'*affectio societatis* permet de se prononcer sur la qualification de société dans des cas douteux où les parties n'ont pas expressément manifesté leur volonté, notamment la reconnaissance des sociétés créées de fait entre concubins, époux ou autres personnes que cette notion a une signification et une valeur pratique (Déjà vu).

3- L'élément intentionnel sert ensuite à distinguer la société d'autres situations voisines tels que l'indivision, le contrat de travail ou de prêt avec participation aux bénéfices.

Voilà pour les éléments constitutifs du contrat de société (S-SI).

Il s'agit des conditions de fond.

SOUS-SECTION II : LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE

Avant l'immatriculation de la société au registre du commerce (art. 210-6 al. 1er C. com. ; 1842 al. 1er C. civ.), une série d'opérations (ou de formalités) doit être accomplie.

§.1 L'exigence de statuts sociaux (Art. 1835 C.civ.)

Les statuts doivent être établis par écrit (art. 1835 C. civ.) : ce sont les règles applicables à la personne morale. A défaut, il n'y aurait qu'une société créée de fait qui ne serait pas dotée de la personnalité morale. Les statuts doivent contenir les mentions suivantes (art. L. 210-2 C. com.) :

- la forme de la société
- sa durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ; mais la société peut toujours être prorogée
- son appellation
- son siège social
- son objet
- le montant du capital social s'il en existe
- les modalités de fonctionnement de la société

L'intervention d'un notaire est obligatoire lorsque deux époux ou des successibles participent à la constitution de la société (art. 1832-1 al. 2 ; art. 854 C. civ.).

L'engagement des associés de créer la société se manifeste par la signature des statuts. C'est le contrat de société. Mais la société n'acquerra la personnalité juridique qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle reste donc jusque-là une personne morale en formation, que nous verrons plus tard.

§.2 - Les formalités postérieures à la signature des statuts

Six formalités:

1- Les statuts doivent être enregistrés à titre provisoire gratuitement auprès de l'administration fiscale.

2- Un avis de constitution de la société doit être inséré dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social. Cet avis contient les principales énonciations des statuts pouvant intéresser les tiers (art. D. 285 nouveau.).

3- Les fondateurs ou leur mandataire doivent déposer:

- un original des statuts.
- Une copie des actes de nomination des organes de gestion, de surveillance et de contrôle.
- Un exemplaire du rapport du commissaire aux apports s'il en existe.
- Un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds.
- Un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée constitutive.

Ces documents sont remis au centre de formalités des entreprises (* *CFE* *) qui les fait parvenir au greffe du tribunal de commerce en même temps que la demande d'immatriculation.

4- Il appartient au greffier du tribunal de commerce de vérifier la régularité de la constitution avant de procéder à l'immatriculation de la société (art. 30 D.; 20/05/84 modifié par D. 10/04/95).

Le greffier doit procéder à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. Si le dossier est complexe, le délai est porté à cinq jours.

L'immatriculation en ligne est désormais autorisée.

l'I.N.S.E.E. (* *Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques* *) attribue à la société un numéro SIREN composé de 9 chiffres (* *Système national d'identification et Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements : www.sirene.fr;* et un numéro SIRET par établissement, composé de 14 chiffres.

Le numéro d'immatriculation doit être indiqué sur les factures, tarifs, documents publicitaires, la correspondance de la société (Décret du 3O.5.1984).

(www.euridile.inpi.fr*) ou **(* *36 29 11 11 INFOGREFFE* ou www.infogreffe.fr***).

L'immatriculation a pour effet essentiel de conférer à la société la jouissance de la personnalité morale (art. L. 210-6 C. com). Elle lui permet également de retirer les fonds provenant de la libération des parts sociales ou des actions (art. L. 223-8 al.1er, 225-11, 225-12 et 226-1 C. com.).

5- Le greffier doit, dès réception du numéro d'identification par l'I.N.S.E.E., insérer un avis au B.O.D.A.C.C., qui sera annexé au Journal Officiel (* *Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales* *). Cet avis contient les renseignements essentiels ayant trait à la société constituée.

6- Des déclarations d'existence doivent être également faites aux services fiscaux (* *contributions directes, T.V.A.* *) et aux organismes sociaux : U.R.S.S.A.F. (* *Union pour le Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales* *), aux caisses de retraite et au Pôle Emploi (l'A.S.S.E.D.I.C : *Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce* + ANPE : *Agence nationale pour l'emploi* + l'AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes).

SECTION III – LES SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION

Le non-respect des règles impératives de formation est sanctionné par la nullité. Cette sanction est inadaptée au droit des sociétés. C'est pourquoi le législateur a adjoint à la nullité des procédures de régularisation et de mise en jeu de la responsabilité des fondateurs et premiers dirigeants. La nullité – Les effets de la nullité

SOUS-SECTION I : LA NULLITE DE LA SOCIETE IRRÉGULIÈRE

C'est une sanction exceptionnelle. Le législateur veut éviter que les associés et les tiers de bonne foi n'en subissent les conséquences.

§.1– Les causes de nullité de la société

5 causes :

1- Le non-respect des dispositions générales à tout contrat :

Il s'agit de la nullité fondée sur la violation des règles de l'article 1108 du Code civil. Dans les SARL et les sociétés par actions, la nullité ne peut résulter d'un vice du consentement, ni d'une incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs (Art. L. 235-1 C. com. Cass. com. 20.6.89, Bull. 40 199). Mais la nullité peut provenir d'autres causes propres aux contrats.

2- Le caractère illicite ou immoral de l'objet social ou de la cause du contrat de société :

La société qui aurait un objet ou une cause illicite ou immoral(e) ou qui n'aurait pas été constituée dans l'intérêt commun des associés est nulle (art. 1833 C. civ.).

3- Le non-respect des éléments constitutifs du contrat de société :

La société est nulle dans les cas suivants :

1- absence d'au moins deux associés, sauf s'il s'agit d'une société unipersonnelle;
2- absence ou fictivité d'un apport;
3- défaut d'affectio societatis;
4- défaut d'intérêt commun des associés.

4- Le non-accomplissement des formalités de publicité :

Le Code de commerce sanctionne d'annulation l'inaccomplissement des formalités de publicité uniquement dans les sociétés en non collectif et en commandite simple. Cette nullité demeure quand même exceptionnelle, car une régularisation est toujours possible en cas d'omission d'une formalité.

5- L'existence d'une fraude : *Fraus omnia corrumpit* (la fraude corrompt tout) :

La nullité de la société pourrait être prononcée en cas de fraude.

En principe, la fraude ne produit d'effet que dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple. Cependant, la Cour de cassation *a érigé la fraude en cause générale de nullité des sociétés.*

§.2 – La procédure d'annulation : l'action en nullité de la société

Quelles sont les personnes qui peuvent agir en nullité ?

Quand la nullité tend à protéger un intérêt particulier, seule la personne ou le groupe de personnes dont la loi a voulu assurer la protection peut agir en nullité : c'est la nullité relative.

Lorsque la nullité sanctionne un vice de portée générale, la nullité est absolue et peut être invoquée par toute personne pouvant se prévaloir d'un intérêt légitime au succès de sa prétention (art. 31 nouv. C. pr. civ.) à savoir notamment : les associés, leurs créanciers personnels, les dirigeants de la société, les créanciers sociaux.

Cependant, il existe deux obstacles à l'exercice de l'action en nullité

1- La prescription

L'action en nullité est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (art.235-9 C.com.), sauf en cas de fraude.

2- La régularisation

Le législateur facilite la couverture des nullités.

Ainsi, l'action en régularisation est ouverte quand les statuts ne contiennent pas toutes les mentions générales ou les mentions propres à chaque type de société, ou si les formalités prescrites pour la constitution de la société ont été omises ou irrégulièrement accomplies notamment dans les SNC et les SCS.

L'action en régularisation peut être intentée par toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte. Tout intéressé peut mettre en demeure la société de régulariser dans un délai de 30 jours.

SOUS-SECTION II : LES EFFETS DE LA NULLITE DE LA SOCIETE

La nullité entraîne l'anéantissement de l'acte irrégulier de société et, éventuellement, la responsabilité de ceux auxquels l'irrégularité est imputable.

§.1 - Les effets de la nullité sur la société elle-même (ou l'effet non rétroactif de la nullité)

Le tribunal doit obligatoirement prononcer la nullité dès l'instant où les conditions sont remplies.

Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

Cependant, la nullité résultant d'un vice du consentement ou d'une incapacité d'un associé peut être opposée aux autres associés ainsi qu'aux tiers même de bonne foi, mais uniquement par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été vicié. (Art. 1844-16 C.civ., 235-12 C.com.).

Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation (Art.1844-15 C.civ.et 235-10 C.com.).

La nullité d'une société ne produit pas d'effet rétroactif. C'est la règle. Cependant,

1- cette règle, i.e.l'absence d'effet rétroactif ne s'applique pas à la société en formation.

2- Cette règle joue même si la nullité a été prononcée pour objet ou cause illicite.

3- Les tiers ne peuvent invoquer la nullité de la société, afin de se soustraire à leurs engagements.

4- La société est considérée à l'égard des associés comme ayant existé valablement jusqu'à la date de son annulation, laquelle est assimilée à une dissolution.

5- En cas de nullité résultant d'une incapacité ou d'un vice du consentement, l'associé qui a obtenu la nullité pourra l'opposer aux autres associés et aux tiers et reprendre ses apports.

§.2 - La mise en jeu de la responsabilité des auteurs de la nullité (fondateurs et premiers dirigeants)

A- Responsabilité civile ; B- responsabilité pénale

A/- La responsabilité civile des auteurs de la nullité

Trois actions en responsabilité peuvent être exercées auxquelles s'ajoute une possible invalidation des clauses illégales:

1 – La première action en responsabilité vise à obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'annulation de la société (Art. 1844-17 C.civ. et 235-13 C.com.).

2 – La deuxième action a pour objet la réparation du préjudice causé par l'irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation, mais dans le cas où la nullité a été couverte. Il s'agit de récupérer les frais de justice engendrés par l'action en nullité.

3 – La troisième et dernière action permet la réparation du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité

exigée par la loi pour la constitution de la société ou pour la modification des statuts (Art. 1840 et 210-8 C. com.).

4- Les clauses statutaires contraires à une disposition impérative et dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité, sont réputées non écrites (art. 1844-10). Exemple: la clause supprimant ou limitant le droit d'accès d'un associé aux assemblées générales.

B/- La responsabilité pénale des auteurs de la nullité

Voici quelques cas où la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée :

- La loi (article 242-1 C. com.) punit les fondateurs et dirigeants de SA qui auront émis des actions, sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. (150.000€ d'amende : le double dans les SA faisant une offre au public de titres financiers).

- La loi (article 242-2 C. com.) punit ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle (5 ans d'emprisonnement et 9000€ d'amende). Les fondateurs, les dirigeants, les associés et les commissaires aux apports pourraient être concernés par cette sanction.

CHAPITRE II – LA CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE

I- Conditions ; II- Conséquences

SECTION I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITE MORALE A LA SOCIETE

L'article 1842 du Code civil dispose que: **" *les sociétés… jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation* "**. Il en résulte que la personnalité morale est attribuée artificiellement, fictivement, par l'ordre de la loi.

SOUS-SECTION I - LE SORT DES ACTES CONCLUS PAR LES FONDATEURS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

§.1 - La notion de société en formation

Jusqu'à l'immatriculation, il n'existe qu'un contrat de société. La société est dite en période de formation dont le début se situe avant la constitution, donc avant la signature des statuts, et dont la fin se situe à la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce, ou au jour où le juge saisi requalifie la société en formation en société créée de fait.

Une société en formation peut dégénérer en société créée de fait (Cass. com., 26 mai 2009).

§.2 - Le principe de prise en charge par la société des actes conclus par les fondateurs (au sens large : Art. 210-6 C. com. Art. 1843 C. civ.).

ou

[Le sort des actes conclus avant et après la signature des statuts, avant l'immatriculation]

1- S'agissant des actes passés avec des tiers (*bailleurs, banquiers, fournisseurs, salariés*), le principe est que seule la responsabilité des personnes qui ont agi au nom de la société est engagée. Mais une jurisprudence récente (Cour d'appel de Versailles, mars 2009) semble vouloir mettre à la charge des associés de fait la responsabilité des actes accomplis par un non-associé.

2- S'agissant des actes internes passés entre associés, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations (article 1842 alinéa 2 du Code civil).

§.3 - La reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation dès l'immatriculation

A- reprise automatique ; B- reprise par décision postérieure

A/- La reprise automatique du seul fait de l'immatriculation

La reprise automatique porte à la fois sur les actes accomplis avant (*1*) et après (*2*) la signature des statuts.

1- La reprise des actes passés avant la signature des statuts. Les actes accomplis pour le compte de la société en formation doivent être annexés aux statuts. La signature des statuts emportera reprise automatique des actes par la société quand elle sera immatriculée. Faute d'annexer aux statuts l'état des actes réalisés, la reprise ne peut se produire automatiquement.

C'est la société qui se substituera aux fondateurs dès son immatriculation.

2- La reprise des actes passés après la signature des statuts, mais avant l'immatriculation. Ici, également, les personnes agissant au nom de la société en formation sont indéfiniment et solidairement responsables, sauf si la société, après avoir été régulièrement immatriculée, reprend les engagements passés. Toutefois, les associés peuvent donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements bien déterminés pour le compte de la société. Dans ce cas, l'immatriculation emportera reprise automatique de ces engagements par la société. Tout engagement qui serait souscrit en dehors des termes précis du mandat ne lierait pas la société.

Pour la Cour de cassation (2008), l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise automatique de cet engagement par ladite société.

B/- La reprise par décision postérieure à l'immatriculation

A la suite de son immatriculation, la société peut valablement reprendre, totalement ou partiellement, par une décision expresse des associés, les engagements qui ont été souscrits en son nom durant la période de formation mais qui ne figuraient ni sur l'état annexé aux statuts ni dans le mandat spécial, (Art. 1843 C. civ.).

Les actes qui ne seraient pas repris resteront à la charge des personnes qui les auront accomplis.

SOUS-SECTION II - LA PERSONNALITE MORALE A L'EPREUVE DES MUTATIONS ET DES CRISES (PORTEE ET LIMITES DE LA PERSONNALITE MORALE)

4 situations méritent d'être distinguées :

§.1 - La transformation de la personnalité morale

Une société peut changer de forme et cette transformation peut se produire par suite d'une disposition légale ou par l'effet de la volonté des associés. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle... L'entreprise continue dans un autre cadre.

§.2 - La survie de la personnalité morale en cas de liquidation (pendant la...)

Pendant la période de liquidation, et pour les besoins de cette liquidation, la personnalité morale de la société dissoute va être maintenue ; le liquidateur agira en justice au nom de la société.

§.3 - La prorogation de la personnalité morale à l'arrivée du terme

Une société peut décider de se proroger. Les associés doivent se réunir un an au moins avant la date d'expiration du terme à l'effet de statuer sur la prorogation de la société. Cette prorogation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

Les associés peuvent librement fixer la nouvelle durée, sans pouvoir retenir une prolongation supérieure à 99 ans.

§.4 - L'abus de la personnalité morale

L'abus de la personnalité morale est constitué dès lors que la société créée est fictive (*ou de façade*) ou frauduleuse. Il en va ainsi lorsque la société a été créée en vue d'une fraude à la loi ou au droit des tiers, comme les créanciers (déjà vu).

Les deux critères qui permettent de révéler la fictivité de la société sont : * L'absence de l'*affectio societatis*, * La confusion des patrimoines. La sanction prononcée est le plus souvent la nullité de la société abusive.

Exemples : création de sociétés morcelées, à moins de 50 salariés, pour éviter de créer un comité d'entreprise ; fraude aux droits du conjoint (*arrêt Demuth*), etc.

L'habileté fiscale est permise. Ainsi, le fait d'organiser son insolvabilité afin d'échapper au recouvrement de l'impôt peut entraîner l'exercice de l'action paulienne de la part du Trésor.

Fort heureusement, l'abus en droit fiscal est peu retenu par les tribunaux notamment s'il existe d'autres motifs légitimes : financiers, juridiques, familiaux ou organisationnels...

SECTION II - LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE

SOUS-SECTION I - L'INDIVIDUALISATION DE LA SOCIETE

Le nom ou l'appellation, le domicile ou le siège social, la nationalité. S'y ajoute sa qualité civile ou commerciale.

§.1 - L'appellation de la société (le nom social)

Toute société doit avoir une appellation figurant dans ses statuts. La dénomination sociale peut être tirée de l'objet de l'entreprise ; elle peut être une dénomination de fantaisie ou comporter le nom d'un ou plusieurs associés. La dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la forme de la société, et du montant du capital social s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une SARL.

Il est recommandé de déposer la dénomination sociale comme marque de service auprès de l'INPI (*Institut National de la Propriété Industrielle*) qui a en mémoire la totalité des appellations de sociétés.

La propriété d'une dénomination sociale est acquise par le premier usage personnel et public. Toute société qui, la première, a utilisé une dénomination peut interdire aux autres de l'employer.

Le changement de dénomination sociale n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

§.2 - Le siège social

Toute société doit avoir un siège social, qui est mentionné dans les statuts. Lorsque la société est assignée en justice, elle doit l'être devant le tribunal du lieu où elle est établie ou dans le ressort des succursales, agences ou directions régionales pour les opérations effectuées par ces dernières.

Le siège social est situé au lieu du principal établissement, là où se trouvent les organes de direction et les services administratifs. Il est donc souvent distinct du lieu d'exploitation.

Le siège social peut être fictif pour bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, ou d'aides à la création d'entreprise. Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour déterminer le siège social réel.

Depuis loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le transfert peut être décidé par un ou plusieurs associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales (C. com. art. L 223-30, al. 1 modifié).

Par exception à cette règle, la loi autorise le gérant à déplacer le siège dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et, sur seconde consultation, à la majorité des voix (C. com. art. L 223-18, al. 8).

Si le transfert s'effectue vers l'étranger et entraîne un changement de nationalité, l'accord unanime des associés est en principe exigé.

Normalement, le siège social est fixé dans les locaux dont la société a la jouissance privative.

Cependant, la **domiciliation peut être collective** : plusieurs sociétés ont un siège social commun.

La domiciliation peut être définitive au domicile du futur représentant légal de la société.

Il existe des sociétés de domiciliation. Les locaux qu'elles proposent doivent être adaptés et répondre aux besoins élémentaires des organes de direction des sociétés domiciliées **(ce qui n'est pas le cas d'un local de 40 m2 loué à 58 sociétés).**

§.3 - La nationalité de la société

Deux critères sont utilisés par le droit français pour déterminer la nationalité de la société : le siège social et le contrôle. Le premier est le critère de principe ; le second est l'exception. Le siège social doit être sérieux et réel.

Une société change exceptionnellement de nationalité, sauf modification dans le contrôle. La décision d'opter pour une nationalité étrangère doit être prise à l'unanimité dans les SCS et les SARL (Art. 222-9 et 223-30 C.com.).

Dans les sociétés anonymes, la décision pourrait être prise en assemblée générale extraordinaire (AGE) à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale. La société conservera ainsi sa personnalité juridique (Art. 225-97 C.com.).

Le transfert du siège social est admis au profit des sociétés européennes (SE) à l'intérieur des Etats de l'UE.

Les Sociétés internationales ne sont pas rattachées à une loi nationale déterminée. Elles sont instituées par des conventions

internationales, *par exemple : (la B.I.R.D.: banque internationale pour la reconstruction et le développement)*.

S'agissant des sociétés multinationales (*IBM.,Nestlé.,Général Electric...*), la société mère et chacune des filiales implantées dans plusieurs pays ont leur propre nationalité. La nationalité des filiales peut cependant être celle de la société mère en cas de siège fictif ou en application des critères du contrôle.

§.4 - La qualité civile ou commerciale de la société

La qualité civile ou commerciale d'une société est un élément de son individualisation.

Les sociétés civiles ne peuvent effectuer que des opérations de caractère civil. Elles sont donc civiles par l'objet : les activités libérales (* *SCP, SCM, SPFPL* *), l'agriculture (* *GAEC, GAF* *), la construction immobilière, l'activité d'enseignement, …

Les sociétés commerciales accomplissent des actes de commerce c'est-à-dire des actes d'intermédiaire. La plupart sont dotées de la personnalité morale.

En vertu de l'art. 210-1 C.Com. :

«*Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet, les SNC, les SCS, les SARL et les sociétés par actions*».

Cet article est générateur de conflits entre la forme et l'objet.

En effet, jamais une société à objet civil ne pourra être considérée comme civile si elle emprunte la forme d'une société commerciale. Il

en va ainsi des sociétés d'exercice libéral (SEL : SELARL, SELARLU, SELAFA, SELCA, SELAS, SELASU).

Les sociétés commerciales relèvent du Tribunal de Commerce. Les sociétés civiles relèvent du TGI.

Dans les sociétés commerciales, la preuve est libre. Dans les sociétés civiles, c'est la preuve par écrit pour les actes ayant une valeur supérieure à 1500€.

Les sociétés civiles sont soumises à l'IR. Les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés de personnes, sont soumises à l'IS.

SOUS-SECTION II - L'AUTONOMISATION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE

§.1 - La distinction entre patrimoine des associés et patrimoine social

Le patrimoine social est le patrimoine propre de la société. Il s'enrichira ou s'appauvrira au gré des résultats financiers. Il se distingue du patrimoine des associés.

Les associés ne sont pas copropriétaires des biens qu'ils ont apportés à la société. Ils ne sont titulaires que de droits sociaux (*parts sociales ou actions*) comportant des droits financiers (*droit aux bénéfices, au boni de liquidation...*) et politiques (*droits d'accès aux assemblées, de vote, à l'information...*). Si la société tombe en cessation des paiements, le redressement ou la liquidation judiciaire ne s'applique, en principe, qu'à elle seule.

§.2 - Le droit des créanciers de la société sur le patrimoine social

Les créanciers de la société ont un droit de gage exclusif sur le patrimoine social par rapport aux créanciers personnels des associés.

Dans les sociétés de personnes, les créanciers sociaux ont également un droit de gage sur le patrimoine de chacun des associés tenus indéfiniment et solidairement en cas de carence de la personne morale.

Les créanciers personnels des associés ne pourraient saisir que les parts ou actions des associés qui sont leurs débiteurs, ainsi que les sommes que la société pourrait devoir à ses associés.

SOUS-SECTION III - LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS L'ORDRE INTERNE ET DANS L'ORDRE EXTERNE

§.1 - Aptitude de la société à être titulaire de droits et à ester en justice (dans l'ordre interne)

On distingue ici la capacité d'exercice de la capacité de jouissance. La capacité de jouissance (Art. 1123 C. civ.), c'est l'aptitude d'une société commerciale à être titulaire de tous droits pécuniaires et extra-pécuniaires.

En revanche, pour pouvoir exercer ses droits, et c'est la capacité d'exercice, la société doit recourir à des personnes physiques.

La personne morale est représentée par les organes (*organes légaux ou sociaux*) que la loi a institués.

La société est en droit d'agir en justice aussi bien comme demandeur que comme défendeur. Elle peut également se constituer partie civile devant les juridictions répressives.

La société est représentée en justice par ses dirigeants réguliers. Ceux-ci peuvent donner à un tiers une délégation spéciale pour exercer au nom de la société une action en justice déterminée.

§.2 - Les rapports de la société avec les tiers (la protection des tiers). Dans l'ordre externe.

C'est une question en relation avec les pouvoirs des dirigeants.

Les tiers peuvent redouter que le représentant légal n'ait pas été nommé dans des conditions régulières, ou ne soit pas investi des pouvoirs nécessaires à la conclusion des actes déterminés par les statuts. Le droit des sociétés s'est efforcé de pallier ces incertitudes par **trois mesures :**

1ère mesure - Les textes réputent régulière la désignation (*ou la cessation des fonctions*) d'un représentant légal qui a fait l'objet d'une mesure de publicité.

2ème mesure - S'agissant des pouvoirs des dirigeants à l'égard des tiers, il faut distinguer selon que la société est à risque limité ou illimité.

1- Dans les sociétés à risque limité (*SARL, SA, SAS, SCA*), les dirigeants engagent la société vis-à-vis du tiers de bonne foi, même pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social.

Seulement, la société pourra engager la responsabilité personnelle du dirigeant fautif.

2- Dans les sociétés à risque illimité (*SC, SNC, SCS*), le gérant engage la société pour les seuls actes qui entrent dans l'objet social. En revanche, la société n'est plus engagée à l'égard du tiers si l'acte dépasse l'objet social.

3ème mesure - Quel que soit le type de sociétés, **les restrictions (limitations) statutaires des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers, même de mauvaise foi, sauf en cas de fraude**.

SOUS-SECTION IV - LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIETE

Une personne morale a-t-elle une conscience ? Peut-on lui imputer des fautes engageant sa responsabilité ?

§.1 - La responsabilité civile de la société

Celui qui s'estime victime des agissements d'une société peut lui demander réparation du dommage qu'il a subi en se fondant sur la responsabilité contractuelle (*Exemple : inexécution, mauvaise exécution*) ou délictuelle.

Une société répond des fautes qu'elle commet par ses organes agissant dans l'exercice de leurs fonctions (Cour de cassation Ch.com. 3 juin 2008).

On soulignera particulièrement l'impact du développement durable en droit des sociétés et dans le domaine des procédures collectives.

Toutes les causes de responsabilité délictuelle visée aux articles 1382 et suivants du Code civil peuvent être invoquées.

Ex: - *concurrence déloyale - acte du salarié dans l'exercice de ses fonctions, art. 1384 al. 5, etc... - fait des animaux - fait des choses dont la société a la garde - fait de la ruine d'un bâtiment*,…

En pratique, la société peut être condamnée solidairement ou in solidum avec son représentant légal.

§.2 - La responsabilité pénale de la société

Le Code pénal énonce que : « *les personnes morales à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement ... des infractions commises, pour leur compte, par les organes ou représentants...* »

Désormais, par exemple, la SNCF peut être poursuivie à la suite d'accidents et non plus seulement les conducteurs de train.

La responsabilité pénale peut être mise en oeuvre pour toutes les infractions prévues par le Code de commerce, par le Code pénal et pour de nombreux délits et infractions prévus par des textes extérieurs. Il convient d'en citer : l'abus de biens sociaux, la distribution de dividendes fictifs, les homicides et violences involontaires, notamment les accidents du travail, le risque de mort causé à autrui, le vol, l'escroquerie, les abus de confiance, l'atteinte aux systèmes informatiques, la corruption active, le trafic d'influence, la violation de la réglementation économique, l'atteinte à l'environnement...

Les personnes morales sont responsables pénalement, en tant qu'auteurs ou complices, de toute infraction commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, (article 121-2 du Code

pénal). Par conséquent, il est nécessaire de caractériser la faute commise par eux (Cass. crim., 25 juin 2008).

Dans tous les cas, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (art. 121-3 CP).

Quelles sont les sanctions pénales qui pèsent sur les personnes morales ?

Chaque infraction est sanctionnée d'une amende dont le taux maximal pour les personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (Art. 131-38 C.P : 10 fois en cas de récidive).

Un crime ou un délit commis par une personne morale peut être sanctionné des peines suivantes : dissolution, interdiction à titre définitif ou temporaire, placement sous surveillance judiciaire, fermeture des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, exclusion des marchés publics, interdiction de faire une offre au public de titres financiers, interdiction d'émettre des chèques, confiscation, affichage (*Art. 131-39 C.P*).

Les personnes morales ont un casier judiciaire.

LECON II

LES ACTEURS DE LA SOCIETE

CHAPITRE I - LES DIRIGEANTS SOCIAUX

Ils sont chargés d'exécuter les décisions des assemblées et, plus généralement, d'assurer la gestion courante des affaires de la société.

SECTION I - LA DESIGNATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX

§.1 - La désignation en situation normale

C'est l'assemblée des associés qui désigne les dirigeants sociaux. Les majorités requises et les modalités de désignation varient selon le type et la taille de la société.

Dans les petites sociétés, capital et pouvoir sont indissociables.

Dans les grandes sociétés, on parle plutôt de managers professionnels.

Dans les sociétés unipersonnelles, l'associé unique peut se désigner lui-même comme dirigeant social. Il doit être une personne physique dans les EURL, et peut être une personne morale dans les SASU. Il peut également nommer un dirigeant social extérieur, non associé.

Dans les SNC, SCS, SCA, dans les SARL et dans les sociétés civiles, la gestion de la société est confiée à une ou plusieurs personnes appelées " *gérants* ". La gérance peut être donc collégiale, (Art 221-3 , 222-2 et 223-18).

Dans les SA, deux architectures sont à distinguer :

1 – 1ère architecture : Les sociétés anonymes de type classique (avec Conseil d'administration) sont administrées par un organe collégial appelé " *Conseil d'administration* ". Le CA a un président appelé (*président du conseil d'administration*) qui peut être en même temps *directeur général* (PDG).

2 – 2ème architecture : Les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance (*CDS*) La gestion repose ici sur la distinction entre les fonctions de direction (directoire) et le contrôle de cette direction par le conseil de surveillance, (Art. 225-57 à 225-93).

Il arrive que la société soit dirigée par un **dirigeant de fait** (une personne physique ou morale qui, sans avoir un mandat social, s'immisce dans la marche de la société, en exerçant des activités positives et continues de direction et de contrôle, en toute souveraineté et indépendance, aux lieu et place du dirigeant de droit, avec lui ou sous son couvert).

La nomination et la cessation des fonctions des dirigeants sociaux de droit doivent être publiées.

Certaines activités et certains statuts sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant social. Ainsi, les fonctionnaires, les parlementaires, les membres du gouvernement et certains officiers ministériels (huissier, administrateur judiciaire, mandataire-

liquidateur,…) ne peuvent avoir la qualité de gérant ou d'administrateur, c.à.d. d'exercer une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit sauf dans certains cas pour les avocats et les notaires.

Ces mêmes incompatibilités frappent également les avocats à moins que la société ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

De même, toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de diriger, de gérer ou d'administrer une société (art. 625-2 et -8 c.com.) ne peut être nommé administrateur d'une SA ou gérant d'une SARL.

Aussi, les statuts peuvent prévoir certaines conditions spéciales positives (avoir tel diplôme) ou négatives (ne pas avoir tel comportement).

Les dirigeants sont rémunérés pour leurs fonctions de dirigeants et ne sont pas liés es qualité à la société par un contrat de travail.

Dans les SARL, la rémunération des gérants est déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés. Le gérant qui fixerait seul sa rémunération pourrait être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Dans les SA, c'est le CA qui détermine la rémunération du président et du DG (art 225-47 et -53). Les administrateurs perçoivent des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles pour des missions bien déterminées (225-44 et s.).

Le conseil d'administration et le conseil de surveillance doivent mesurer les performances accomplies par les dirigeants, et les dire

suffisantes, pour que la société puisse verser aux intéressés ce qui leur a été promis.

Un code de gouvernance a été élaboré par le MEDEF. Il renforce l'encadrement des rémunérations, limite le nombre de mandats des mandataires sociaux, reconnaît les administrateurs salariés et met en place un Haut Comité chargé de s'assurer que les dispositions du code sont respectées.

Certains dirigeants de SARL et de SA peuvent cumuler un contrat de travail avec leurs fonctions de dirigeant, sous certaines conditions, l'objectif étant de moraliser la vie des affaires.

Dans les SARL,:

1- Le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif; il ne doit pas être fictif.

2- Il doit correspondre à des fonctions techniques distinctes des fonctions de gérant et donner lieu à deux rémunérations distinctes.

3- Le gérant doit être dans un état de subordination à l'égard de la société. Ainsi, le gérant majoritaire, égalitaire ou celui qui détient le monopole du savoir, ne peut cumuler un contrat de travail.

4- Le contrat de travail est une convention réglementée qui doit être soumise à l'approbation des associés.

Dans les SA, le cumul est très réglementé (article 225-122) :

1- Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société;(contrat de travail nul + restitution des salaires perçus).

2- Un salarié peut devenir administrateur sans perdre le bénéfice du contrat de travail, à condition que ce contrat soit effectif et donne lieu à une rémunération distincte.

3- Depuis le 24 mars 2012, il est admis pour un administrateur de SA, comptant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions €, de devenir salarié si son contrat de travail de travail correspond à un emploi effectif. L'antériorité de statut de salarié n'est plus exigée.

4- Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction sauf en cas d'une reprise de la société par ses salariés -RES (art. 225-22 c.com. et 220 quater A-I, al. 6 CGI).

5- Le président du CA peut cumuler un contrat de travail dans les mêmes conditions qu'un administrateur. Mieux vaut suspendre le contrat de travail pendant le temps d'exercice du mandat de président.

6- Le Directeur Général (DG), s'il n'est pas administrateur, peut cumuler un contrat de travail_avant ou après l'accès aux fonctions de DG (dans les deux sens: salarié/DG ou DG/salarié), dans le respect des autres conditions prévues pour les administrateurs et pour le PCA.

Par ailleurs, le législateur réglemente le cumul des mandats par des personnes physiques:

1- Une personne physique ne peut exercer plus de 5 mandats d'administrateur ou de membre de CDS de SA ayant leur siège sur le territoire français sauf dans les sociétés de groupes.

2- Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de DG ou de membre de directoire (ou de directeur général unique) sauf dans les sociétés de groupes.

3- Le PCA peut cumuler jusqu'à 5 mandats (art. 225-49).

Si une personne viole ces dispositions, elle doit démissionner dans les trois mois. A défaut, elle est démise d'office avec l'obligation de restituer les rémunérations (art. 225-21 al3; 225-54-1 al3; 225-67 al3; 225-77 al3; 225-94-1 al3).

§.2 - La désignation des dirigeants sociaux en situation de crise

Les associés peuvent être confrontés à des crises sociales graves. Lorsque le juge est sollicité, il peut désigner des tiers qui vont, plus ou moins, s'immiscer dans le fonctionnement de la société. Lorsqu'il y a urgence, le juge des référés, peut nommer un administrateur provisoire (*AP*).

Deux conditions doivent être réunies pour que le juge accède à la demande de nomination d'un AP.

1/ Il faut que soit apportée la preuve d'une paralysie des organes sociaux suite à une mésentente caractérisée entre associés.

2/ Il faut qu'un péril imminent et certain menace la société.

Sa décision est toujours fondée sur l'intérêt social.

Exemple : Deux groupes d'associés égalitaires, détenant chacun 50% du capital social, à la suite de mésententes graves et persistantes, bloquent toute résolution ou décision sociale pendant plusieurs mois.

La mission de l'AP est temporaire. Il peut être investi de tous les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants.

En pratique, sa mission est limitée à un ou plusieurs actes déterminés : Exemples : l'exécution d'une commande ; la vérification des comptes, la location du fonds de commerce de la société…

SECTION II : LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS SOCIAUX

§.1 - L'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux

Les pouvoirs des dirigeants sont davantage déterminés par la loi que par le contrat qui les lie à la société (*en ce qui concerne leur statut social*). C'est " *le principe du pouvoir légal* ".

Deux situations sont à distinguer :

1- Dans les rapports avec les associés, les dirigeants d'une société à risque illimité et ceux d'une SARL peuvent, en principe, faire *tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société (C. civ., art. 1848 SC, 221-4, 222-2, 223-18: SNC, SCS, SARL)*.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus par les textes. Chacun doit contrôler les opérations de son cogérant et peut s'opposer à tous les actes accomplis par ce dernier.

2- Dans les sociétés par actions, les dirigeants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs des assemblées des

actionnaires (art. L 225-35 et 225-51: SA, 226-7: SCA et 227-6 pour les SAS).

- Une clause des statuts peut limiter les pouvoirs des organes de gestion (C. civ., art. 1848 al. 3, art. 221-4, 223-18, 225-35, 225-51, 225-64) : par exemple la vente d'un fonds de commerce exploitée par la société est soumise à une autorisation préalable des associés.

- Certains contrats sont expressément interdits aux dirigeants, personnes physiques. Par exemple, interdiction de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (art. 223-21,225-43,225-91). **Ce sont des conventions interdites.**

En revanche, certaines conventions sont autorisées entre la société et ses dirigeants ou associés mais elles sont soumises soit à une autorisation préalable dans les SA, soit à un contrôle souvent postérieur dans les SARL. **Ce sont les conventions réglementées.**

Par ailleurs, les dirigeants sont tenus à une obligation de non-concurrence : La jurisprudence impose aux dirigeants un devoir de loyauté envers la société et les associés.

Le dirigeant ne saurait non plus utiliser sa position d'ancien dirigeant d'une société pour lui faire concurrence déloyale dans une autre société.

Il doit respecter, le cas échéant, la clause de non-concurrence, s'il en existe, qui le lie à la société à condition que cette clause ne soit pas disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace.

En effet, La signature des statuts par un gérant non associé accompagnée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de gérant » ne suffit pas à lui rendre opposable une disposition statutaire lui interdisant tout acte de concurrence après la fin de son mandat (Cass.com. 10 juillet 2012).

Quels sont les principaux actes relevant de la compétence des dirigeants sociaux sont au nombre de quatre:

1 - Les actes se rattachant à leurs fonctions d'autorité : embauche, surveillance, licenciement et rémunération des salariés.

2 - Les actes se rattachant à l'administration du patrimoine social :

- les réparations, le renouvellement du matériel…
- la location des locaux, le règlement des dettes de la société.

3 - Les actes relatifs à l'exercice de l'activité économique de la société : l'achat de matières premières, la vente de marchandises, les opérations courantes de crédit...

4 - En revanche, s'agissant des **actes d'aliénation ou de disposition de biens sociaux**, de la constitution de sûretés ou de la modification du mode d'exploitation de l'objet social, le dirigeant doit veiller à la fois au respect de la poursuite de l'objet social, de l'intérêt social et des dispositions légales. Une autorisation préalable des associés est souhaitable et parfois exigée par les textes (*Art 223-19, 225-38 et s.*).

Les dirigeants sociaux peuvent, dans le respect des statuts, déléguer à d'autres personnes de leur choix (*appelés fondés de pouvoir*) le pouvoir d'accomplir au nom de la société, certains actes déterminés à caractère technique, administratif, financier ou comptable.

Mais ils ne peuvent déléguer tous les pouvoirs.

Ils peuvent également déléguer leur signature.

§.2 - L'aggravation des responsabilités des dirigeants sociaux

Civile, pénale, révocation (A, B, C).

A/ - La responsabilité civile des dirigeants sociaux

Deux types d'actions peuvent être exercés contre les dirigeants. Elles se prescrivent par trois ans.

1 – Les actions individuelles

La responsabilité personnelle est prévue à l'égard de la société, des associés et des tiers, en cas d'infraction aux lois et règlements, de violation des statuts et de faute de gestion. Deux types de fautes :

(1) Les fautes par omission : défaut de surveillance des cadres supérieurs, des employés, absence de comptabilité analytique, lancement de projets sans étude préalable sérieuse.

(2) Les fautes par commission : lancement d'opérations aventureuses et démesurées, actes de concurrence déloyale, diversification désordonnée des activités sociales, concurrence personnelle par personne interposée aux affaires sociales, …

La faute de gestion est en réalité un manque de bon sens. Elle doit être appréciée à la date de sa commission.

La jurisprudence accorde le bénéfice de l'action individuelle à l'associé contre le dirigeant non contre la société, pour obtenir la réparation d'un préjudice qui lui est personnel, par exemple, en

cas de détournement par le dirigeant des dividendes qui devaient revenir à l'associé.

Le dirigeant manque à son devoir de loyauté s'il n'informe pas l'associé, lorsque celui-ci cède ses parts ou ses actions, de circonstances de nature à influencer son consentement, tel le fait qu'une négociation est en cours avec un tiers pour un prix supérieur. (Cass. com. 12 mars 2013).

Le dirigeant qui achète, pour son compte personnel, l'immeuble dans lequel sa société exploite son activité, à l'insu des autres associés et en sachant que ceux-ci projetaient de l'acquérir, manque à son obligation de loyauté et engage sa responsabilité à leur égard. Il leur doit réparation (Cass. com. 18 décembre 2012).

En revanche, lorsque l'action individuelle est exercée par un tiers véritable contre le dirigeant, la jurisprudence subordonne sa responsabilité à **"une faute séparable - ou détachable - de ses fonctions".**

Il s'agit d'une responsabilité délictuelle personnelle.

Ainsi, est responsable le dirigeant qui commet intentionnellement une faute « d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ».

<u>Exemples :</u>

- Les dirigeants qui s'obstinent à violer les règles sur la contrefaçon dont se rend coupable la société, commettent une faute détachable de leurs fonctions.
- Le gérant est responsable envers un fournisseur impayé par la société, pour avoir passé une commande qu'il savait que la société ne pouvait pas ignorer, et donc payer.

2 - Les actions sociales

La loi prévoit deux actions sociales. Elles sont destinées à réparer un préjudice propre à la société : par exemple, un détournement de fonds sociaux par un dirigeant.

*** La première est l'action sociale *ut universi*** qui est exercée par les représentants légaux de la société. Elle est souvent exercée par le nouveau dirigeant contre celui qui a été révoqué en raison de ses fautes, ou par un gérant contre un cogérant.

*** La seconde est l'action *ut singuli*** qui est exercée, par un ou plusieurs associés détenant une qoute-part dans le capital social (art. 223-22: 10% SARL , 225-252: 5% SA). Son utilité est de pallier l'inertie des dirigeants fautifs encore en place. Elle vise la défense de l'intérêt social non l'intérêt propre des associés.

Toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'autorisation préalable de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à celle-ci est réputée non écrite.

« L'action de groupe » ou « class action » est possible depuis le 1er octobre 2014 (loi Hamon).

B/ - La responsabilité pénale des dirigeants sociaux

Malgré la dépénalisation progressive du droit des sociétés (NRE, lois du 1er août 2003) les sanctions pénales restent nombreuses (241-1 à –8 et 242-1 à –9; 243-1; 244-1; 248-1). Le droit pénal commun (escroquerie, faux en écriture, abus de confiance) ne suffit pas à sanctionner les dirigeants sociaux.

a) - Dans les sociétés à risque limité (SARL, SA, SAS, SCA), des délits spécifiques sont prévus. Les délits les plus importants et les plus fréquents sont au nombre de 4:

1 - L'abus des biens et du crédit (*ABS*)

Le délit d'ABS s'applique aux gérants de SARL et aux dirigeants de SA qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement (SARL: Art. 241-3-4°; SA: Art 242-6-3°. Ex: Affaires Testut, Valéo Crédit Foncier, Mouillot, Carrignon…), (5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende).

2- L'abus des pouvoirs ou des voix :

L'abus des pouvoirs ou des voix peut être défini comme étant l'usage des pouvoirs du dirigeant à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Exemple: le dirigeant a reçu la majorité absolue des voix grâce aux procurations, et il en profite pour engager la société sans qu'il n'y ait un avantage à l'égard d'une autre société dont il est l'associé unique.

Le dirigeant coupable est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende (SARL: Art. 241-3-5°; SA: Art 242-6-4°).

3 - La présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, en vue de dissimuler sciemment la véritable situation de la société (*SARL : 241-3-3°, SA : 242-6-2° :* 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende).

N.B. Des comptes annuels infidèles sont susceptibles de causer un préjudice au créancier de la société à qui ils sont présentés. Celui-ci est donc fondé à s'en plaindre devant le juge d'instruction (Cass. crim. 25 juin 2013)

4 - La distribution de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux (*art. 241-3, 242-6, 243-1, 244-1, 248-1 :* 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende).

b) - Dans les sociétés à risque illimité, il n'existe pas de délits spécifiques. Par ex, l'ABS n'est pas réprimé. Mais le droit pénal commun s'applique (abus de confiance, escroquerie + quelques délits liés à la publicité légale et aux fonctions de commissaire aux comptes).

Enfin, les dirigeants sociaux répondent, en tant que chef d'entreprise, des infractions à la réglementation générale des entreprises et de celles révélant un défaut de surveillance ou une imprudence :

1/ **Exemples** : infraction au droit du travail, de l'environnement, de la consommation, du code de la route…

2 / **Exemples** : homicide involontaire.

C'est le dirigeant qui est condamné qui paie les amendes non la société.

N.B. Un décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 réglemente à la prévention et à la réparation de certains **dommages causés à l'environnement**.

[Son champ d'application est limité à certaines atteintes à l'environnement seulement :

- **Il définit les autorités compétentes pour imposer les mesures de prévention et de réparation des dommages,**
- **Il impose les modalités d'informations sur les mesures adoptées par l'exploitant et l'administration,**
- **Il organise l'adoption et le suivi des mesures de réparation en cas de dommage,**
- **Il formalise la possibilité d'intervention de tierces personnes en lieu et place de l'exploitant non identifié**
- **et il envisage des peines contraventionnelles en cas de manquement à certaines de ses dispositions].**

C/ - Une autre sanction : la révocation des dirigeants sociaux

La responsabilité civile et pénale du dirigeant n'exclut pas la possibilité de sa révocation dans l'ordre interne.

1- Dans les SA, les administrateurs, les Présidents, les membres du CDS sont révocables ad nutum sur simple signe de la tête, sans justification, ni préavis, ni indemnité et sans que leur révocation ne soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale (225-18 et 225-105). Mais, la révocation ne doit pas intervenir dans des conditions injurieuses, brusques et vexatoires (Art. 2004 C. civ.,

225-47, 225-75). Dans ce cas, elle donnerait lieu à des dommages et intérêts.

Pour respecter les droits de la défense, un motif de révocation doit être communiqué au dirigeant avant la décision, même dans les cas où la révocation sans juste motif ne donne pas lieu à dommages-intérêts. C'est un revirement de jurisprudence (Cass. Com 14 mai 2013).

L'administrateur d'une SA s'étant « abstenu de se rendre tant au conseil d'administration ayant précédé l'assemblée générale au cours de laquelle son éviction a été décidée qu'à cette dernière [...] s'est ainsi de lui-même exclu des débats et ne peut dès lors se plaindre d'une violation de ses droits ».

Aussi, même en l'absence de débat contradictoire, le dirigeant ne peut faire valoir que sa révocation était abusive (Cour de cass.com. 10 juillet 2012).

La révocation d'un dirigeant n'est pas abusive dès lors qu'il a été informé des motifs de celle-ci et qu'il a pu présenter ses observations avant le vote de la décision, peu important que la procédure se soit déroulée très rapidement (Cass. com. 10 février 2015).

De même, la société n'a pas à ouvrir une discussion préalable à la décision de révocation lorsque le dirigeant a exprimé préalablement ses points de désaccord et, par une démarche personnelle, a posé des conditions à la continuation de ses fonctions (Cass. com. 14 avril 2015).

En revanche, le DG, les membres du directoire et le DGU sont révocables à tout moment, pour juste motif. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et

intérêts sauf si le DG assume en même temps les fonctions de PCA (225-55, 225-61).

2- Dans les SNC, SARL, SCS, SCA et Soc. civ. le gérant peut être révoqué soit par les associés (pour juste motif), soit par décision de justice (pour cause légitime). Le gérant injustement révoqué a droit à des dommages et intérêts.

Qu'est-ce que le juste motif ?

Le juste motif doit consister en une faute de gestion ou doit être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société (voir les exemples sur la faute de gestion).

Dans les SARL, la révocation, comme la nomination (223-18 qui renvoie à 223-29), est prononcée à la majorité absolue (Art. 223-25 qui renvoie à l'article 223-29).

Dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habilité à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés.

La révocation du gérant de la société doit être jugée abusive dès lors qu'il a reçu quitus de sa gestion pour la période au cours de laquelle des fautes seraient alléguées à son encontre et que lesdites fautes n'ont pas été invoquées au soutien de la décision de révocation. La condamnation de l'associé majoritaire, dont le vote a conduit à la révocation du gérant, à des dommages et intérêts impose l'établissement par le juge de l'existence d'une volonté de nuire constitutive d'une faute personnelle (Cour de cassation Ch. com. 12 février 2013).

CHAPITRE II - LES ASSOCIÉS

Droits – Pouvoirs – Sauvegarde de la qualité d'associé

SECTION I - LES DROITS DES ASSOCIÉS

Droits politiques – Droits financiers et patrimoniaux

§.1. Les droits politiques

En vertu de l'article 1844 C. civ. " *tout associé a le droit de participer aux décisions collectives* ". Cette prérogative revêt deux formes :

Information - vote

La première forme : Le droit d'information de l'associé sur les comptes sociaux et la politique sociale :

- Les dirigeants doivent communiquer aux associés un certain nombre de documents: inventaire, comptes annuels et comptes consolidés, liste des administrateurs et des membres de CDS, rapports du CA, du directoire, du CDS et des commissaires aux comptes, exposé des motifs des résolutions, les rémunérations, les conventions courantes;
- Les associés peuvent poser des questions par écrit à la suite de cette communication: **Art. 1855 C. civ. Art. 221-8 : SNC, 223-26 : SARL, 225-115 et s : SA).**
- Ce droit est permanent et périodique : il se manifeste par le déclenchement de la procédure d'alerte (art. 223-36 et 225-232) ; il peut être exceptionnel : il se traduit par le recours à l'expertise de gestion, à condition de détenir 10% du capital social dans les SARL et 5% dans les SA (art. 223-37 art. 225-231). Les associés doivent d'abord poser des questions avant d'engager l'expertise de gestion. L'article 225-232 leur offre la

possibilité de poser des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'entreprise.

<u>La deuxième forme : Le droit de vote</u> permet à l'associé de participer aux décisions ordinaires et extraordinaires, stratégiques de la société (*augmentation du capital social, réduction du capital social, nullités...*). Il lui permet de contrôler les dirigeants en les révoquant au besoin. Ce droit est en principe égalitaire (Art. 223-28 : SARL et Art 225-122 : SA), mais des inégalités légales sont prévues et des inégalités conventionnelles sont permises dès lors qu'elles ne sont pas léonines.

Telle est la conséquence du mouvement de contractualisation qui affecte les sociétés et qui consacre en les encadrant les actions de préférence.

Ainsi, un associé de SAS exclu par un vote auquel il ne pouvait prendre part est réintégré dans la société. La stipulation interdisant à un associé de SAS dont l'exclusion est envisagée de prendre part au vote est contraire aux règles impératives sur le droit de vote. La clause d'exclusion s'en trouve inapplicable dans son ensemble et la décision d'exclusion est donc nulle (Cass. com. 9 juillet 2013).

Est valable la convention par laquelle les fondateurs d'une société s'engagent à voter, lors des assemblées générales, dans le sens déterminé à la majorité lors de réunions préalables organisées entre eux (CA Paris 4 décembre 2012).

Ainsi, il existe plusieurs variétés d'actions dans les SA :

* Les actions à droit de vote double (Art. 225-123 et -124 C. com.),

* La possibilité de limiter le nombre de voix de chaque associé (Art. 225-125),

* Les actions de préférence avec ou sans droit de vote ; elles sont assorties de droits particuliers de toute nature, à titre permanent ou temporaire, pour une durée déterminée ou déterminable,

* Les actions à droit de vote multiple dans les SAS (Art. 227-1 et s. combinés avec les articles 228-11 et s.).

Dans les SNC et SCS, un associé est égal à une voix.

§.2. Les droits financiers et patrimoniaux

Les associés reçoivent, en principe, proportionnellement à leurs parts ou actions, des dividendes qui correspondent à la distribution des bénéfices réalisés. Là aussi, une répartition inégalitaire, non léonine, est possible. Les associés participent également au boni de liquidation, à la dissolution (*c'est le dividende final*) de la société.

Les parts ou actions font partie du patrimoine social. Elles ont une valeur vénale. L'associé peut les céder (à l'exclusion des parts en industrie), dans le but de réaliser une plus-value, le cas échéant. Une telle cession est libre ou exige une majorité plus ou moins élevée selon le type de société et la volonté des associés exprimée dans les statuts, et surtout selon que les titres sont ou non cotés en bourse.

A/- La cession des parts sociales dans la SARL

Trois situations méritent d'être distinguées:

1- La cession ou la transmission entre membres de la même famille:

Le principe : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté des biens

entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants (Art. 223-13).

L'exception : Toutefois, les statuts peuvent prévoir une clause statutaire d'agrément qui ne peut intervenir que dans les conditions de majorité prévue à l'article 223-14 à savoir: la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. C'est la double majorité (par têtes et par titres). Une majorité plus forte ne peut être exigée.

En cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec son héritier (*ab intestat* et non légataire) ou seulement avec les survivants. Dans l'hypothèse où la société continue avec les seuls associés survivants ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Les statuts peuvent stipuler que la SARL pourra continuer, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec toute personne désignée par les statuts, ou si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

Dans tous les cas de cession précités, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès **(selon la procédure de l'expertise de l'article 1843-4 C.civ).**

2- La cession à des tiers étrangers à la société :

Cette cession exige la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (Art. 223-14). C'est la double majorité par tête et par titres (notification aux autres associés, acceptation dans les trois mois ou dans le silence de la société). En cas de refus d'agrément, quatre situations sont envisageables :

1- soit le cédant renonce à la cession. C'est le droit de repentir ;

2- soit les associés acquièrent eux-mêmes les parts ou les font acquérir par un tiers ;

3- soit c'est la société qui rachète les parts en réduisant le capital social.

4- Soit, à défaut, la cession initialement prévue par l'associé se réalise.

Dans les GIE et SNC: c'est l'unanimité qui est d'ordre public qui est exigée, (Art. 221-13) et dans les sociétés civiles: c'est l'unanimité qui est exigée, sauf clause statutaire contraire (Art. 1865 C. Civ).

3- La cession entre associés:

Les parts de SARL sont librement cessibles entre associés. Mais les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément limitant la cessibilité. En ce cas, c'est la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (Art.223-16 qui renvoie à l'article 223-14) qui est exigée. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus à l'article 223-14.

N.B. L'associé qui a cédé ses titres au dirigeant sans que celui-ci l'informe de négociations parallèles en vue de la cession de tout le capital social à un tiers peut réclamer au dirigeant des dommages-intérêts pour la plus-value de cession dont il a ainsi été privé (CA Paris 17 septembre 2013).

B/- La cession des titres dans les SA

Dans les SA non cotées, la cession des titres peut être soumise, à l'égard des tiers et entre actionnaires, à l'agrément de la société par

une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant (228-23).

N.B. Une clause de préemption est toujours possible. Elle donne la priorité, en cas de cession, à un ou plusieurs actionnaires.

L'objectif du législateur est de préserver l'équilibre des pouvoirs au sein des SA non cotées.

Une faculté de renonciation, **un droit de repentir,** est accordée au cédant (Art.228-24). Elle est sans délai dans les SA, avec délai dans les SARL.

Il convient de noter que les titres peuvent être d'utiles instruments de garantie et peuvent faire l'objet d'un nantissement au profit d'un créancier (*le nantissement est un contrat réel de garantie. C'est un gage sans dépossession portant sur les valeurs mobilières*). La cession des parts sociales ou actions s'accompagne de garanties légales et ou conventionnelles. Si elle est massive, on l'appelle cession de contrôle.

SECTION II - LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

Deux sortes de pouvoirs et de modalités d'exercice.

§.1. Les pouvoirs de gestion et de contrôle des associés

1 - Le pouvoir de gestion

Les associés détiennent le pouvoir de décider, dans les grandes circonstances, du sort de la société : sa transformation, sa dissolution, le changement de sa nationalité, la modification des statuts notamment à l'occasion d'une augmentation ou d'une

réduction de son capital. Mais la majorité requise n'est pas toujours la même en raison de l'importance de telle ou telle autre décision.

Les majorités requises :

• L'unanimité est requise pour :

- *la nomination des commissaires aux apports dans les SARL*, **Art. 223-9 et -33 et s.**

- *la majoration du montant nominal des actions dans les SA*, **Art. 225-127 et s.**

- *la continuation avec les héritiers ou avec les survivants dans les SNC*, **Art. 221-15**

- *la transformation de la SARL en SNC, SCS, SAS ou SCA*; **Art. 223-43 et s.**

- *la transformation de la SA en SNC;* **Art. 225-245 et s.**

- *la transformation de la SA en SAS*; **Art. 227-3**

• La double majorité par têtes (en nombre d'associés) et par titres (en nombre de parts sociales) est requise pour la *cession des parts à un tiers, conjoints, ascendants et descendants, par voie de succession et entre associés dans les SARL* ***(Art.223-13, -14, 15, -16*)**. C'est une majorité à caractère supplétif pouvant être renforcée ou réduite par les statuts selon le cas.

• La majorité qualifiée: C'est la majorité *des 2/3* dans les SA et dans les SARL. Elle est exigée pour :

- *L'augmentation et la réduction du capital social:* **Art. 223-30, 225-129 et 225-204**

- *la transformation de la SARL en SA et inversement :* **Art. 223-43**

- la transformation de la SCA en SA ou SARL : **Art. 226-14 : AGE majorité des 2/3 des commanditaires+ majorité des commandités**

- la fusion ou la scission **: Art. 236-2 et s.**

- la transformation de la SA en SCS, SCA : **Art. 225-245 et s : majorité des 2/3 commanditaires + unanimité des commandités.**

● La majorité absolue: c'est la majorité de plus de 50% (50% + 1 action ou part sociale). Elle est requise pour l'approbation des comptes et des conventions réglementées, l'affectation des résultats de l'exercice et la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont les associés ont la disposition, la révocation des dirigeants,…Certaines majorités sont d'ordre public.

● La majorité relative: c'est la majorité des présents ou représentés, qui s'obtient souvent sur deuxième convocation aussi bien dans les SA que dans les SARL en matière de nomination et de révocation des gérants de SARL et de dirigeants de SA.

Voici pour le pouvoir de gestion des associés.

2 - Le pouvoir de contrôle

Deux types de pouvoirs: contrôle général, contrôle spécial

1- Les associés disposent d'un pouvoir de contrôle général dans le cadre de l'assemblée annuelle appelée à statuer sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels. Ils peuvent les approuver ou les désapprouver, donner un quitus de gestion ou refuser ce quitus aux dirigeants. Ce pouvoir de contrôle est une arme redoutable qui traduit effectivement l'équilibre entre les organes de

gestion et les associés, voulu par le législateur (*Art. 221-7 SNC; 223-26 SARL ; 225-100, 222-1 et s., 242-10 et s. SA et autres*).

2- Les associés disposent également d'un pouvoir de contrôle spécial des conventions conclues entre la société et les dirigeants ou associés pouvant être jugées très désavantageuses pour celle-ci (*Art. 223-19 SARL, 225-38 et s. et 225-86 SA*).

Dans les SARL, il existe deux procédures de contrôle des conventions réglementées : l'une a priori, l'autre a posteriori.

Dans les SA, le contrôle est préalable.

Sont exclues du contrôle les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (*Art. 223-20, 225-39, 225-87*).

D'autres conventions, en raison de leur danger, sont purement et simplement interdites aux dirigeants personnes physiques, à leurs ascendants et descendants et à certains associés. Exemple : les emprunts, les cautionnements, les avals accordés par la société aux dirigeants et aux associés (*Art. 233-21, 225-43, 225-91, 226-10, 241-3, 242-6 :risque de responsabilité pénale pour ABS*).

§.2. Les modalités d'exercice des pouvoirs par les associés

La particularité de l'exercice des pouvoirs par les associés tient aux modalités de consultation de ces derniers et aux différentes catégories de décisions qu'ils peuvent prendre.

En principe, les décisions sont prises en assemblées qui, en principe, sont le lieu d'exercice du pouvoir suprême. C'est la structure pyramidale des pouvoirs: l'AG est à la base, le CA au milieu, le PCA,

le PDG, le DG au sommet, seulement en théorie. En pratique, c'est plutôt l'inverse qui se produit.

Une Assemblée générale (AG) est

- obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes,
- ou si un ou plusieurs associés représentant une quote-part du capital social demandent sa réunion **(Art. 223-27 : 50% des parts sociales ou 25% des associés représentant 25% des parts sociales, 225-103 et s :à la demande d'actionnaires réunissant 5% , dans les SA).**

Dans certaines sociétés, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles doivent être prises par consultation écrite des associés : le vote par procuration et par correspondance sont également admis, Art. 221-6, 223-27, 225-107, Art. 1853 C. civ .

Le Code de commerce reconnaît la possibilité du vote électronique et ouvre la voie à l'utilisation des moyens modernes de télécommunication (Art. 225-107 C.com.). Il consacre ainsi notamment la visioconférence comme moyen de participation sans présence physique.

Les associés prennent deux types de décisions : ordinaires et extraordinaires.

1 - Les décisions collectives ordinaires portent principalement sur la nomination, la révocation des dirigeants, l'approbation des conventions réglementées, des comptes sociaux et de la répartition des dividendes.

- **Dans les SNC et SCS,** ces décisions sont prises à l'unanimité sauf clause statutaire contraire (*Art. 1852, 221-6*) ;

•**Dans les SA,** ces décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, sur première et sur deuxième convocation (*Art. 225-98*).

- NB. Un quorum est requis (1ère : 1/5 ; 2ème : pas de quorum)

•**Dans les SARL,** les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sur première et sur deuxième convocation (*50 % plus 1 part ou plus si les statuts le prévoient - Art. 223-29*).

- Pas de quorum requis

N.B. L'assemblée générale d'une SARL ayant décidé une augmentation de capital a été annulée pour fraude car elle avait été réunie alors que la société savait que l'un des associés risquait d'être absent et qu'elle n'avait pas pris le soin de le prévenir (CA Aix-en-Provence 13 décembre 2012).

2 - Les décisions collectives extraordinaires, elles portent essentiellement sur les diverses modifications statutaires : changement d'objet social, de dénomination, du siège, de nationalité, augmentation du capital, réduction du capital social, approbation des fusions et scissions, dissolution...

•**Dans les SNC et SCS,** les décisions extraordinaires sont prises à l'unanimité sauf clause statutaire contraire (art. 221-6 C.com).

•**Dans les SA et SARL (depuis 2005),** les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires ou associés présents ou représentés, sur première et sur deuxième convocation (*Art. 223-30 et 225-96*)

- NB. Un quorum est requis : 1ère : 1/4 ; 2ème : 1/5

En contrepartie des droits et des pouvoirs, les associés sont tenus à des devoirs et obligations : celui de contribuer aux pertes, celui de libérer les apports, l'obligation de non-concurrence... Ils doivent prendre leurs décisions sans abus qu'ils soient minoritaires, égalitaires ou majoritaires.

D'où l'abus de majorité, l'abus de minorité, et l'abus d'égalité, qui appellent l'application de la théorie générale de l'abus de droit dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir :

1/ la décision a été prise contrairement à l'intérêt social. Pour les minoritaires et les égalitaires, c'est souvent un acte bloquant la réalisation d'une opération profitable à la société.

2/ la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ou inversement, i.e. au détriment de l'ensemble des autres associés dans l'unique dessein de favoriser leurs intérêts propres.

Le seul refus d'un associé minoritaire de voter un projet essentiel pour la société ne suffit pas pour caractériser un abus de minorité. Il faut caractériser en quoi il est abusif !

SECTION III- LA SAUVEGARDE DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ

L'associé entre librement dans la société ; il est libre d'y demeurer sans que ses engagements ne puissent être augmentés. Mais il a le droit de se retirer sous certaines conditions. Il peut même être exclu exceptionnellement : <u>exclusion</u>, <u>retrait</u>, <u>intangibilité</u>.

§.1. L'exclusion de l'associé

L'interdiction d'exclure un associé est un principe reconnu par la jurisprudence depuis l'***Arrêt Nollet du 12 mars 1996*) ["*, Aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d'obliger l'associé qui demande la dissolution de la société par application de l'art. 1844-7-5° C. civ. à céder ses parts à cette dernière et aux autres associés qui offrent de les racheter* "].**

Cependant, le droit de rester dans la société n'est pas absolu. Il peut être écarté dans les SAS (*227-16*).

Le législateur autorise l'exclusion de l'associé dans les cas suivants :

1- dans les sociétés à capital variable (*Art. 231-6, al.2*),

2- lorsque la société fait l'objet d'un plan de sauvegarde (*Art. 626-4*), ou lorsque les dirigeants d'une société soumise à une procédure collective, sont frappés de faillite personnelle (*et 653-9)*

3- lorsque l'incapacité ou le vice du consentement d'un associé risque d'entraîner l'annulation de la société (*Art. 235-6*),

4- lorsque les associés, après mise en demeure, ne libèrent pas, les sommes restant à verser sur le montant des actions souscrites par eux (*Art. 228-27*; dans les SNC : *Art. 221-16*). La société poursuit la vente des dites actions.

5- dans l'hypothèse particulière de la réduction du capital social à zéro (art. 224-2 : exclusion naturelle et logique),

6- dans l'hypothèse d'une réduction du capital qui se réalise par une réduction du nombre d'actions avec élimination corrélative des actionnaires ne possédant pas le nombre minimum requis (art.225-204),

7- Le groupe majoritaire à 95 % peut imposer le rachat de leurs actions aux minoritaires (*Art. 5-7-1 du Conseil des marchés financiers*),

8- de même, les statuts peuvent prévoir l'exclusion d'un associé dans des situations clairement déterminées, sans abus, ni arbitraire. C'est l'exclusion statutaire. (*Cass. com. 21.10.97 ; Bull. Joly 98 p. 40*).

Exemple : plusieurs sociétés créent une filiale commune.

Si l'une d'entre elles passe sous le contrôle d'un concurrent, elle doit céder ses droits aux autres (*C'est une forme d'exclusion*).

Rappel : La stipulation interdisant à un associé de SAS dont l'exclusion est envisagée de prendre part au vote est contraire aux règles impératives sur le droit de vote. La clause d'exclusion s'en trouve inapplicable dans son ensemble et la décision d'exclusion est donc nulle (Cass. com. 9 juillet 2013).

§.2. Les modalités de retrait de l'associé

L'associé ne doit pas être prisonnier de son titre. Mais il n'est pas toujours libre de quitter la société. Ses droits sont transmissibles. Il peut les céder soit à un associé ou un tiers, soit il propose à la société de les lui racheter.

<u>- Tout d'abord la cession</u> (déjà vu au § 2 consacré aux droits financiers et patrimoniaux): La cession est libre dans les SA cotées ; elle peut être soumise à agrément dans les autres SA à l'égard des tiers et entre actionnaires (Art. 228-23, -24).

En revanche, la cession est minutieusement réglementée dans les autres formes sociales où elle est soumise à agrément soit à une majorité qualifiée légale (double majorité) ou statutaire (*Art. 223-13 à 16 SARL*), soit à l'unanimité (*Art. 221-13 : SNC*).

Nous en avons déjà parlé.

<u>- En second lieu, le rachat :</u> En principe, un associé ne peut pas exiger le rachat de ses droits sociaux par la société, mais il ne peut pas, non plus, en rester indéfiniment prisonnier. En droit, le retrait est autorisé dans certains sociétés et groupements où *l'intuitu personae* est présent **(Dans les sociétés civiles, Art. 1869 C. civ. , dans les SEL en participation, Art. 1871 et s. C. civ. 23 al. 2 L. du 4 janvier 1978, dans les GIE (*Art. 7 ord. 1967*), mais aussi dans les sociétés à capital variable (*Art. 231-6*).**

En pratique, le retrait se rencontre lorsqu'il y a changement de majorité dans les sociétés cotées notamment. L'associé majoritaire a l'obligation de racheter au même prix les actions des minoritaires si ceux-ci le souhaitent (*cette question est débattue*) : C'est le retrait des minoritaires.

L'associé qui se retire demeure tenu du passif existant avant que le retrait n'ait été rendu opposable aux tiers.

Se pose la question de la valeur des parts de l'associé sortant. L'article 1843-4 du Code civil (Modifié par l'Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 37) dispose que :

« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

§.3. L'intangibilité des engagements de l'associé

L'art. 1836 C. civ. dispose que : " *en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci* ".

Le contrat de société est la loi des parties. C'est un texte de droit commun qui s'applique à toutes les sociétés. Il est d'ordre public. Selon la Cour de cassation, " Les engagements des actionnaires ne

sont augmentés que si les dispositions prises par l'assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers" (Cass.civ. 9/2/37 D.P. 1937.1.73).

L'AGE ne peut imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre son gré (Art.225-96 pour les SA et 223-30 pour les SARL); elle ne peut pas non plus bloquer son compte courant, le contraindre à adopter une clause statutaire d'exclusion, ni l'obliger, dans les SNC, à verser des fonds complémentaires.

De même, l'unanimité est exigée lorsque la SARL ou la SA se transforme en SNC ou lorsque une clause interdit à l'associé sortant toute forme de concurrence.

La Cour de cassation distingue clairement, d'un côté l'augmentation de l'engagement des associés qui ne peut résulter que d'une modification des statuts à l'unanimité, et de l'autre, les décisions prises conformément aux statuts, par exemple, une clause statutaire qui prévoit la participation de tous les associés à une augmentation du capital social à terme, dans un délai déterminé. Dans ces cas, il n'y a pas d'augmentation des engagements, dans la mesure où tous les associés ont signé les statuts et approuvé cette clause. Par conséquent, l'unanimité n'est pas exigée pour mettre en œuvre cette clause.

LEÇON III
LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

La société, comme une personne physique, a vocation à disparaître à un moment de sa vie. Cette disparition peut être naturelle ou provoquée par ses membres ou prononcée par les juges. La dissolution de la société entraîne sa liquidation et le partage de son patrimoine.

- Les causes, - Les effets

CHAPITRE I - Les causes de la dissolution

- De plein droit, - provoquée

SECTION I : La dissolution de plein droit

1. L'arrivée du terme

A l'arrivée du terme, la société est dissoute, art. 1844-7 1° C. civ. Sauf prorogation. La durée de la société est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du jour de son immatriculation (art. L.210-2, D.2 al. 1). Mais elle peut toujours être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, art 1844-6 C.civ. , art. D.2 al.2. A défaut de prorogation et si les associés continuent l'exploitation, une société de fait apparaît entre eux pour les activités réalisées postérieurement à l'arrivée du terme.

2. La réalisation ou l'extinction de l'objet social (art. 1844-7 2°)

La réalisation de l'objet social suppose que l'opération pour laquelle la société a été instituée se trouve définitivement achevé et ce, même si

le terme statutaire (percement d'un tunnel ou d'un canal, assèchements de marais...) n'est pas encore atteint.

Il y a également extinction de l'objet lorsque l'activité pour laquelle la société a été instituée se révèle impossible (objet déclaré illicite, révocation d'une concession ; fermeture judiciaire d'un fonds de commerce qui était l'unique objet de l'exploitation sociale, non-respect des exigences professionnelles).

L'extinction peut n'être que partielle, et dans ce cas, la société subsiste.

En pratique, les statuts, le plus souvent, prennent soin de définir un objet suffisamment large pour ne pas dire très large. Par ailleurs, il est toujours possible, en cours de vie sociale, de modifier l'objet social et de l'étendre si nécessaire. Lorsqu'une société cesse en fait ses activités, elle est mise en sommeil et peut reprendre à tout moment son activité. Cependant, à l'expiration d'un délai de trois ans, s'il n'y a pas eu reprise, le greffier doit procéder à la radiation de la société qui équivaut à une dissolution (art. 23, 42-3°, 43 D. 30 mai 1984).

3. La dissolution prévue dans d'autres dispositions statutaires (art. 1844-7, 8°)

Les statuts peuvent prévoir que la société sera dissoute par la survenance d'un événement déterminé notamment dans les filiales communes (modification de la situation juridique ou financière de l'un des associés ; Art. L.223-41; accumulation de résultats déficitaire, suppression d'un régime fiscal privilégié...).

4. L'annulation du contrat de société

L'annulation de la société est rare car le législateur s'est montré très réservé quant aux nullités en matière de société. Cependant, si elle intervient, la dissolution est la sanction normale, art. 1844-7, 3° ; 1844-15 al.1 et 2 C. civ. ; L.235-10. C.com.

5. La liquidation judiciaire de la société

Le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société entraîne automatiquement la dissolution de celle-ci. Il en va de même du jugement qui, dans le cadre d'un plan de redressement, ordonnerait la cession totale des actifs de la société (art. 1844-7-7°C. civ. issu de la loi du 5 Janvier 1988).

6. La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main

Lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main à la suite d'une cession ou d'une transmission successorale, la société n'est plus dissoute de plein droit. Un délai d'un an est accordé à la société pour qu'elle opère sa régularisation (art. 1844-5 C. civ. ; art. L 223-4 sur la transformation en société unipersonnelle : voir Leçon 1, ch.1, section 2, les développements faits sur ce point).

Dans l'attente de la régularisation, la société continue à fonctionner normalement comme auparavant et le gérant-associé unique concentre sur sa tête tous les pouvoirs des organes sociaux (ester en justice, se maintenir dans les lieux...), le but étant d'éviter la confusion des patrimoines. Mais, l'associé unique ne devient pas responsable sur ses biens personnels des dettes de la société. Sa responsabilité dépendra toujours du type de société concernée. Il peut dissoudre à tout moment ou subir une dissolution judiciaire (1844-5 C.civ.)

Dans les textes en vigueur, les changements totaux d'associés n'entraînent pas de cessation de la personne morale d'origine, ni création d'un être moral nouveau (Cass. 3ème civ., 7 avr. 1994 ; Rép. Min. n° 79368 à M. Jean-Pierre Marcon : JOAN Q, 21 sept. 2010, p. 10332; JCP-E- n° 40, 7 Octobre 2010, 1880).

Voilà pour la dissolution de plein droit

SECTION II : La dissolution provoquée

- Conventionnelle, - judiciaire

1. La dissolution conventionnelle anticipée (par décision des associés)

Les associés peuvent à tout moment, en cours de vie sociale, décider la dissolution anticipée de la société (art. 1844-7, 4°). C'est bien entendu une décision grave. Elle ne peut être prise qu'aux conditions exigées par la loi ou les statuts pour les modifications statutaires. Cependant, la dissolution anticipée ne doit pas être inspirée par une intention frauduleuse ou par l'intention de nuire à la minorité.

2. La dissolution judiciaire anticipée (pour inexécution de ses obligations par un associé) (art. 1844-7-5°)

Ce motif est une application de l'article 1184 du Code civil sur la résolution des contrats pour inexécution. Il a peu l'occasion de jouer.

Exemple

La défaillance d'un associé qui aurait promis un apport en industrie et qui serait dans l'incapacité d'effectuer le travail promis (défaillance involontaire, infirmité habituelle...).

3. La dissolution judiciaire anticipée (pour mésentente entre associés)

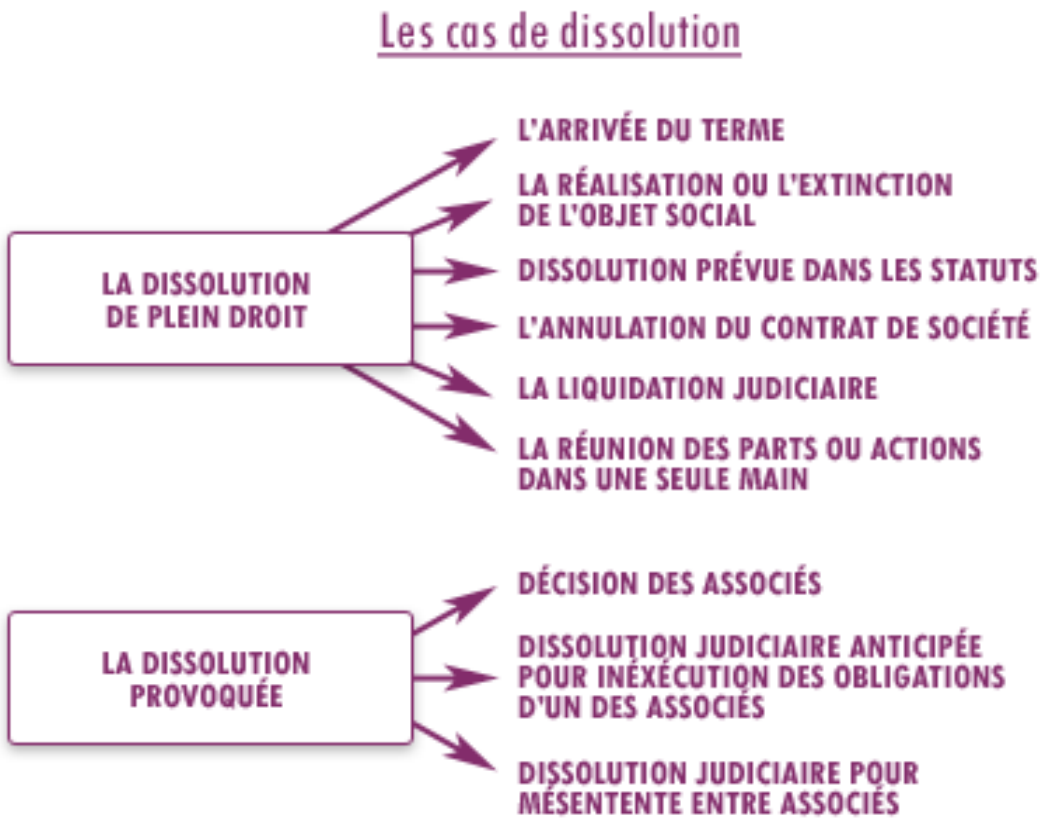
Les tribunaux ne font droit à cette demande de dissolution qu'avec beaucoup de réserve :

- La mésentente doit être grave et de nature à paralyser le fonctionnement de la société.

Exemples de justes motifs: absence de majorité ou l'existence d'une égalité paralysante entre deux groupes d'associés, impossibilité d'avoir un ou plusieurs organes sociaux dans les SA et dans les SCA notamment, conflit exacerbé entre les deux seuls associés...

- Lorsque la société est prospère, les juges tenteront préalablement de faire dénouer la crise en désignant un administrateur provisoire (voir les développements faits à ce sujet).
- La dissolution peut être prononcée dans tous les cas où l'affectio societatis fait défaut et même en cas d'abus de majorité sans qu'il y ait paralysie de la société (Cass.com 18.5.1982, Rev.soc.1982 p. 804 note Le Cannu).
- L'action en dissolution est d'ordre public et ne peut donc être soumise à aucune restriction des statuts. La demande en dissolution impose de mettre en cause la société.
- L'action en dissolution relève de la compétence du tribunal de commerce (Art.D. 51 et 198). Elle doit être intentée de bonne foi. Si elle est exercée de façon abusive, le demandeur peut être condamné à des dommages et intérêts (Biblio. : Cass.com.13 février 1996 RJDA 5/96, 641). Les juges apprécient souverainement la valeur des motifs allégués en se plaçant au moment où ils rendent leur décision.

Le jugement de dissolution ne produit pas d'effet rétroactif.



SECTION III: La publicité de la dissolution

Cf. supra la régularisation.

A. Les formalités de publicité (de la décision de nomination du liquidateur ; art L.237-2, 237-3, 247-6 C.Com)

- JAL,
- GREFFE,
- RCS,
- BODACC.

La dissolution entraîne immédiatement la liquidation de la société, mais elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après **sa publication.**

B. L'opposabilité de la dissolution aux tiers

L'opposabilité est l'objet même des formalités de publicité ci-dessus. La dénomination sociale doit être suivie de la mention *« Société en liquidation »*. Une société dissoute ne peut plus être rétablie ni transformée par la volonté des associés. Ceux-ci doivent constituer une nouvelle société.

CHAPITRE II - Les effets de la dissolution

- La liquidation, - le partage des biens sociaux, - les conséquences fiscales

SECTION I : La liquidation de la société

La liquidation d'une société est l'ensemble des opérations consécutives à sa dissolution. Elles ont pour objet de régler le passif, de convertir les éléments d'actif en argent (en liquide), en vue de procéder au partage entre les associés de l'actif net subsistant.

Au cas où il n'y aurait pas d'excédent d'actif, l'opération doit également déterminer la part de chaque associé dans le passif. Le Code de commerce, réglemente de façon très détaillée la liquidation en organisant tout particulièrement le contrôle des associés sur l'activité des liquidateurs. Art. L. 237-2 à 237-31. Art. R-266 à 280 D).

A. La survie de la personnalité morale

La personnalité morale de la société survit à sa dissolution. Pendant la période de liquidation il est nécessaire que le patrimoine social reste attaché à la personnalité de la société (créances à récupérer, contrats à achever, biens à vendre...). Mais cette personnalité ne survit que pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de

celle-ci par l'assemblée des associés ou par décision de justice (art. L. 237-9 à 237-10). La clôture doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution (art. 1844-8 in fine C. civ. ; art. L. 237-21 ; 237-2 al. 1 C.com.).

Même en liquidation, une société a droit à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale en cas d'usurpation de sa dénomination sociale ou de son enseigne par un tiers.

La capacité juridique de la société est limitée pendant la période de liquidation. L'assemblée générale ne peut prendre que des décisions en relation avec les opérations qui commandent la liquidation. Le liquidateur se contente "d'expédier les affaires en cours" sauf exception et avec autorisation (Cass.com. 15 novembre 1994, Bull. Joly 1995, 47 note Le Cannu).

Cependant, certaines opérations, sont expressément autorisées : la fusion, la scission, l'apport global (art. L.236-1). La continuation de l'exploitation pourrait même être exceptionnellement permise (art. L. 237-24 al.3).

La dissolution n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux d'immeubles utilisés pour l'activité sociale, ni la résiliation des baux de locaux d'habitation dépendant de ces immeubles (Art. 237-5 al.2).

B. Le sort des organes sociaux

En vertu de l'art. L. 237-15 et s. C.com. Les pouvoirs des dirigeants sociaux (PDG, CA, Directoire, gérants) prennent fin à la date de la dissolution de la société tant dans l'ordre interne que dans l'ordre externe. Mais ils doivent rendre compte de l'exécution de leur mandat antérieur à la dissolution, dans les 6 mois de la dissolution.

S'agissant des organes de contrôle et de surveillance, deux situations sont à distinguer :

- 1/ Dans l'hypothèse d'une liquidation légale, décidée par voie de justice, ou applicable dans le silence des statuts, la dissolution ne met pas fin aux fonctions du Conseil de surveillance (CDS) ni à celles du ou des commissaires aux comptes : ces organes contrôlent les comptes sociaux présentés par le liquidateur, non les comptes de clôture de la liquidation (CAC), Art. L. 237-14 à 237-31.
- 2/ Dans l'hypothèse d'une liquidation statutaire ou conventionnelle, l'AGE peut mettre fin (en même temps) aux fonctions du CDS et du ou des CAC (Ceux-ci doivent rendre compte des vérifications et des irrégularités constatées jusqu'ici).

C. Les modalités de la liquidation

I-Nomination du liquidateur;

II-mission du liquidateur;

III-surveillance des opérations par les associés ;

IV-responsabilité civile du liquidateur

I – La nomination du liquidateur : Selon le cas, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés dans les statuts, à défaut par les associés, à défaut par voie de justice (art. L. 237-1, L. 237-18, art. L. 407, D. 274 al. 1) . Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers, personnes physiques ou morales (administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur par exemple). Ses fonctions sont limitées à trois ans (art. L. 237-21), en principe.

S'ils sont plusieurs, un seul rapport est établi.

Le renouvellement de son mandat est possible. Il doit être motivé et le liquidateur doit indiquer les mesures qu'il entend entreprendre pour clôturer la liquidation (art. L. 237-21). En cas de faute, le liquidateur peut être révoqué et remplacé (art. L. 237-22). Il peut démissionner de bonne foi ou demander à la justice qui l'a nommé de le décharger

II – La mission du liquidateur : Le liquidateur est désormais le seul représentant de la société (art. L. 237-24 al. 1).
La mission qui lui est confiée est très vaste:

1 - il doit dresser un inventaire de l'actif et du passif et doit prendre les mesures conservatoires qui s'imposent pour protéger l'actif social;

2 - il doit recouvrer les créances sociales ;

3 - il doit réaliser l'actif, même à l'amiable (art. L. 237-24 al. 1). Le législateur a cependant pris certaines précautions destinées à éviter des opérations douteuses (Art. 393 à 396 notamment et art. 488-2°).

Exemples :

- la cession directe ou indirecte à des parents et proches est interdite (art. 237-7 et 247-8 ; Cass.crim.8 décembre 1999 RJDA 5/00 539),

- la cession à un ancien dirigeant ou commissaire aux comptes exige l'unanimité (art. 237-7),

- la cession globale de l'actif par voie de fusion exige la majorité qualifiée ou l'unanimité selon le type de société (art.237-8),

- la cession du bail doit être assortie de garanties,

4 – Le liquidateur doit payer les créanciers de la société, art. L. 237-24 al. 2.

Les créanciers à terme ne peuvent pas exiger un paiement immédiat, sauf convention contraire ou si le débiteur avait diminué par son fait les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

5 – Enfin, éventuellement, le liquidateur doit verser aux associés des acomptes sur liquidation. Mais cette distribution ne peut être faite que sous réserve des droits des créanciers (art. L. 237-31 al. 1). A défaut, le liquidateur engage sa responsabilité pénale (Art. 245-5 et -7).

III – La surveillance des opérations de liquidation par les associés :

- Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur doit convoquer l'assemblée et lui faire rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer (art. L. 237-23 ; art. R. 237-15 C.com.; et sur les sanctions pénales, art. L. 247-7 1°).
- Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur est tenu d'établir l'inventaire, les comptes annuels et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé (art. L. 237-25 al. 1 ; et sur les sanctions pénales art. L. 247-7- 2°).
- Au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, le liquidateur doit convoquer une assemblée des associés à l'effet de statuer notamment sur les comptes annuels (art. L. 237-25 al. 2 et L. 247-7- 4° ; art. L. 237-28 ; art. L. 237-25 al. 2 ; ; art. R. 237-15 C.com.)

- Pendant toute la période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux (art. L. 237-26).

IV - La responsabilité civile du liquidateur : elle peut être engagée pour toutes les fautes dommageables qu'il aurait commises, le préjudice pouvant avoir été subi par les tiers, la société et même par les associés.

Exemples :

Art. L 237-12 et L. 225-254 :

- **non-renouvellement d'un bail,**
- **présentation non fidèle ou incomplète des comptes,**
- **clôture prématurée de la liquidation,**
- **non- paiement des créanciers qui se sont opposés à la vente du fonds de commerce,**
- **omission d'inclure dans les comptes de la société une créance dont il avait connaissance,**
- **défaut d'indication de la mention "société en liquidation", omission de déclarer la société en cessation des paiements...**

De plus, le liquidateur est responsable à l'égard des associés en raison du préjudice personnel que sa faute peut leur causer.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs ne sont pas, en principe, tenus solidairement mais peuvent être tenus pour le tout lorsqu'il n'est pas possible de déterminer pour quelle part la faute de chacun a contribué aux dommages.

Par ailleurs, le non-respect de la plupart des obligations incombant au liquidateur est sanctionné pénalement notamment en cas d'ABS, indépendamment des sanctions pénales propres à chaque cas particulier (art. L. 247-6 à 247-8 : emprisonnement de 5 ans et amende de 9000 €).

Sa responsabilité fiscale peut être également retenue sous forme de dommages et intérêts envers le Trésor public. Le cas se présente notamment lorsque le liquidateur procède à la distribution entre les associés sans s'assurer que les impôts dus par la société ont été payés.

D. La clôture de la liquidation

En fin de liquidation, tous les associés doivent être convoqués par le liquidateur, à défaut, par un mandataire judiciaire, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat. L'assemblée constate également la clôture de la liquidation (art. L. 237-9).

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le liquidateur doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et copie. Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieux et place de l'assemblée (art. L. 237-10, art. R. 237-6 C.com; art. L. 237-11, art. R. 237-7, -8 et -9 C.com. art.247-6).

A partir du moment où la clôture de la liquidation est prononcée, la personnalité morale de la société disparaît (art. L. 237-2 al. 2), et les fonctions du liquidateur cessent.

Cependant, lorsqu'on découvre après l'accomplissement des formalités de publicité, qu'un créancier a été omis ou qu'un litige dans lequel la société était partie n'est pas terminé, la jurisprudence admet que la personnalité morale subsiste. Il convient alors de demander en justice la nomination d'un mandataire ad hoc (art. 875 CPC et art. L. 247-7 C.com. ; Cass. com., 8 juin 2010, SA Héli transport c/ Cie Héli Air Monaco ; JCP-E- n° 27, 8 Juillet 2010, 1664 ; Jean-Pierre Legros).

SECTION II : Le partage des biens sociaux

A. Le déroulement de l'opération de partage (B. Le sort des créanciers sociaux.

Deux étapes :

1. La mise en oeuvre du partage (2. La réalisation du partage)

Le partage entre associés peut commencer en cours de liquidation lorsque le liquidateur a procédé à une distribution sur les fonds disponibles. Mais il intervient en principe après la clôture de la liquidation, et porte sur le boni de liquidation (art. 1844-9 al. 2 C. civ. art. L.237-29 C.com.).

Le partage est généralement amiable. Il pourrait être judiciaire si les associés ne s'entendaient pas, ou si figuraient parmi eux des incapables (art. 823, 838, 466 C. civ.).

Lorsque les biens à partager comprennent des immeubles, l'acte de partage doit revêtir la forme authentique.

Selon le cas, c'est le conseil de famille ou le juge qui autorise le partage par le tuteur au nom du mineur (art.466 al.2, 389-5 al.3 et -6 al.1 Cciv.).

Le partage en nature est la règle mais il est rare (art.826 C.civ.). Le partage se fait généralement en espèces sur le produit de la vente préalable de tous les biens sociaux.

2. La réalisation du partage

Le partage tend à fixer la part de chaque associé dans les valeurs actives et, éventuellement, passives qui résultent du compte définitif de liquidation.

Il est toutefois permis aux associés de décider que certains biens seront attribués à certains associés (attribution conventionnelle). A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport (c'est la reprise d'apports). (art. 1844-9 al. 3 C. civ. et RM. Sénat 01.01 1987 JO p.23).

Deux hypothèses :

1 - Dans l'hypothèse où tout l'actif a été réalisé, s'il reste une somme d'argent à partager, chaque associé commence par recevoir le montant nominal des parts ou actions dont il est titulaire. C'est le remboursement du capital.

Si, après remboursement des apports, il reste un boni de liquidation, celui-ci est réparti entre les associés en fonction des dispositions statutaires. A défaut, la répartition doit s'opérer en proportion de leur

participation au capital social (art. L. 237-29 ; art. 1844-9 al. 1 C. civ.).

En cas de démembrement des parts ou des actions sociales, le boni de liquidation revient au nu-propriétaire mais, sauf convention contraire des parties, il reste soumis à l'usufruit (Art. 587 C.civ.).

Le liquidateur qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus, il s'exposerait à un emprisonnement de six mois et à une amende de 6000 euros (Art. 245-5).

2 - Dans l'hypothèse où le passif n'a pu être intégralement réglé, les associés dont la responsabilité est limitée à leurs apports perdent tout ou partie de ceux-ci (SARL, SA, SAS, SCA et SCS pour les commanditaires). Les associés tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales devront, quant à eux, désintéresser personnellement les créanciers sociaux non payés (SNC, S.CIV...).

Lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie (Cass. 1ère Ch. Civ. 19.4.2005; D.5.5.2005; n° 18; Actu. jp.; p. 1230).

B. Le sort des créanciers sociaux

Lorsque la liquidation est terminée, les créanciers sociaux n'ont plus d'action contre la société. Ils ont cependant une action directe contre les associés si l'actif a été partagé alors qu'ils n'ont pas été désintéressés.

Dans les SA et SARL, l'action directe est limitée aux apports des associés et à ce qu'ils ont reçu dans le partage. Dans les SNC et dans les sociétés en commandite, elle est possible pour le tout. (Art.L237-13 C.com.).

SECTION III : Les conséquences fiscales de la dissolution

A. Les droits d'enregistrement (B. Les impôts sur le bénéfice)

La dissolution de la société est qualifiée de cessation d'entreprise au regard des impôts directs. En principe, la dissolution qui n'emporte aucune transmission de biens meubles ou immeubles est enregistrée moyennant le paiement d'un seul droit fixe de 375 € (ou 500 si la société a un capital d'au moins 225 000€, Art. 811-2 C.G.I.). Elle entraîne l'imposition immédiate des bénéfices et des plus-values non encore taxés.

Il faut distinguer :

1. Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR)

Si des immeubles et des fonds de commerce apportés initialement sont attribués à un associé autre que l'apporteur, selon la théorie de la " mutation conditionnelle des apports " le droit de mutation non perçu lors de cet apport, l'apport initial devient rétroactivement exigible :

- Pour les immeubles : le taux est de 5,09 %;
- Pour les fonds de commerce : les taux progressifs en fonction des fractions de valeur : de 0 % à 3 % ou 5%
- Le partage des biens meubles et immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,5 % (C.G.I. art. 746).

2. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)

La reprise des apports par les associés n'est pas redevable des droits d'enregistrement, faute de mutation. Lorsque des immeubles et des fonds de commerce apportés initialement sont attribués à un associé autre que l'apporteur, les droits de mutation ne sont pas dus puisqu'ils ont déjà été perçus à l'origine.

Quant au partage de l'actif net entre les associés, il donne lieu, en principe, au paiement du droit de 2,5 % (C.G.I. art. 746).

B. Les impôts sur le bénéfice dus en fonction du régime fiscal de la société

Il faut distinguer :

1. Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR)

En ce qui concerne les apports, il s'agit d'un remboursement par la société de sa dette envers ses associés. Il est exonéré.

Quant au partage des réserves entre les associés, il n'est pas imposable, puisqu'elles ont déjà été imposées au nom des associés au moment de la réalisation des bénéfices. En revanche, les associés sont redevables de l'I.R., au taux normal, pour leur part dans les bénéfices d'exploitation.

En savoir plus : Les plus-values dégagées par la cession des immobilisations sont taxées à 34,5 % (19% + 15,5% au titre des prélèvements sociaux) : (C.G.I. art. 151 septies et 202 bis).

2. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)

En cas de dissolution, ces sociétés sont redevables de l'I.S. au taux de 33,33 %.

Quant aux associés, le partage du boni de liquidation est imposé comme une distribution de dividendes. Cependant, ils bénéficient d'un abattement fiscal de 40% pour les associés personnes physiques. En revanche, le remboursement des apports est exonéré.